

ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 쟁점*

— 국내주식을 기초자산으로 하는 ETF를 중심으로 —

이경민**

국문초록

본 연구는 ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 판단기준을 정립한다. 공매도 금지 기간 중 LP에게만 허용된 ‘헤지 목적’ 예외는 형평성 논란을 야기해왔으나, 자본시장법은 정당한 헤지거래의 판단기준을 규정하지 않고 있다. 본 연구는 환헤지·KIKO·ELS 판례 및 주요국 비교법 검토를 통해, 정당한 헤지거래의 기준으로 ① 헤지 대상의 명확한 존재(대상성), ② 투기가 아닌 위험회피 목적(목적성), ③ 실제 위험에 비례하는 규모(비례성)의 3대 원칙을 도출하였다. 또한 ELS 델타헤지 판례와 실무를 반영하여 헤지비율 115%를 감독상 참고기준으로 잠정 제안하고, 리밸런싱 대응, 선물 만기 전환, 블록딜 선행헤지 등 유형별 판단기준을 제시하였다. 주요국과 달리 한국은 헤지거래의 실체적 요건을 명문화하지 않고 있어, 본 연구는 헤지거래의 정의와 헤지비율의 제도화 필요성을 제시한다. 이는 LP의 법적 예측가능성 제고와 감독당국의 일관된 집행기준 마련에 기여할 것으로 기대된다.

□ 주제어: ETF 유동성공급자, 헤지거래, 정당한 시장조성, 공매도 규제

□ JEL: K22, G18

투고일: 2026.1.12.

수정일: 2026.4.6.

게재확정일: 2026.4.24.

* 본 논문의 내용은 개인의 의견을 밝힌 것으로서 소속기관의 입장과는 무관합니다.

** 금융감독원 선임검사역(leekm@fss.or.kr)

I. 서 론

상장지수펀드(Exchange Traded Fund, 이하 ‘ETF’)는 기초자산을 추종하는 펀드를 거래소에 상장하여 주식과 동일하게 실시간 매매할 수 있도록 한 금융상품으로, 2002년 국내 최초 도입 이후 성장을 지속해왔다. 글로벌 ETF 시장은 2010년 이후 연평균 25% 이상 성장하였으며¹⁾, 국내 ETF 시장 또한 2025년 12월 기준 순자산총액 약 297조 원, 상장 종목 수 1,000개를 돌파하였다²⁾. 이러한 성장은 ETF 유동성공급자(Liquidity Provider, 이하 ‘LP’)의 활동이 제도 정착에 기여한 결과이다. LP³⁾는 ETF 시장에서 매수·매도 호가를 지속적으로 제시함으로써 투자자가 합리적인 가격에 거래할 수 있도록 유동성을 제공하는 금융투자업자로서, 이러한 공적 기능 수행의 대가로 일반투자자와 달리 일정한 규제상 편익을 부여받는다.

그러나 LP에 대한 규제상 편익은 지속적으로 사회적 논란의 대상이 되어왔다. 2020년 3월 코로나19 확산에 따른 공매도 금지 조치 기간 중에도 LP는 ‘헤지 목적’ 거래로 예외 인정을 받았으며, 이는 개인투자자들의 강한 반발을 초래하였다⁴⁾. 2023년 공매도 금지 조치 당시에도 동일한 논란이 반복되면서, LP의 차입공매도가 진정한 헤지인지, 혹은 투기·차익거래에 해당하는지에 대한 근본적 의문이 제기되었다⁵⁾.

실제로 국내외 금융시장에서는 ‘헤지거래’를 명목으로 한 투기적 거래로 대규모 손실이 반복적으로 발생해왔다. Société Générale(2008, 방향성 포지션을 헤지로 위장, 49

-
- 1) 김은총·황교선·전상훈, 상장지수펀드(ETF) 보유지분이 기초자산 주식의 가격 모멘텀에 미치는 영향: 한국 시장을 중심으로, 재무연구 제38권 제1호, 2025, 106면. 글로벌 ETF 시장은 2010년 이후 지속 성장하여 2023년 말 기준 미국 ETF 시장 총자산(AUM)이 약 7.3조 달러에 이른다.
 - 2) FnGuide, 국내 ETF 현황, <https://testfnindex.fnguide.com/fund/etf> (최종방문일 2026.1.7.). 2025년 12월 기준 국내 ETF 시장은 총 1,058개 펀드에 순자산 약 297조 원이며, 이 중 국내 주식형 ETF는 394개(37.24%), 순자산 약 95조 원(31.96%)으로 시장의 주요 축을 형성하고 있다.
 - 3) 주식·ELW·ETN 등에도 LP가 있으나, 이 논문에서 특별한 구분 없이 ‘LP’로 표기한 경우는 모두 ETF LP를 의미한다.
 - 4) 동아일보 기사(2020.12.21.), ‘개미 눈총’ 시장조성자 무대 좁아진다...공매도 절반 감소한다; 금융위원회 보도자료(2020.12.18.), 시장조성자제도 개선 및 불법공매도 적발 강화를 통해 자본시장의 신뢰를 제고하겠습니다 (별첨1: 시장조성자 제도개선 기본방향).
 - 5) 조선비즈 (2023.11.7.), 시장조성자 공매도도 금지해달라는 개미들...거래소 “유동성 공급 위해 필요”; 금융위원회 보도자료, (2023.11.5.) 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고, 전향적인 공매도 제도개선을 추진합니다.

억 유로 손실), UBS(2011, 가상 헤지 포지션 입력, 23억 달러 손실), 신한투자증권 (2024, 추가 수익 목적 선물매매를 LP 업무로 위장하고 허위 스왑으로 손실 은폐, 1,300억 원 손실) 등의 사례⁶⁾는 모두 '헤지' 명목의 거래가 실질적으로는 투기적 성격을 띤 거래로 인한 것이었다. 이러한 사건들은 개인의 일탈로 환원될 수 없으며, '정당한 헤지'와 '투기적 남용'을 구별할 명확한 법적 기준과 실효적 감독체계의 부재에서 비롯된 구조적 문제로 보아야 한다.

현행 제도는 두 가지 측면에서 근본적인 한계를 가진다. 첫째, 법적 정의의 부재이다. 자본시장법은 '정당한 헤지거래'의 정의규정을 두지 않고 있으며, 시행령은 공매도 순보유잔고 보고의무 예외사유로 "경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래"라는 추상적 문구만을 제시하고 있다. 거래소 업무규정 역시 LP의 헤지거래 범위나 비례성 기준을 구체화하지 않고 있으며, 감독당국의 가이드라인 또한 존재하지 않는다. 그 결과 LP는 대부분의 공매도 거래를 '헤지 목적'으로 주장할 수 있고, 감독당국은 명확한 기준 없이 사후적 재량판단에 의존할 수밖에 없다. 이는 LP에게는 법적 예측가능성의 결여를, 감독당국에는 집행기준의 불명확성을, 개인투자자에게는 LP 거래에 대한 불신을 초래한다.

둘째, 감독 인프라의 한계이다. 현재 감독체계는 LP의 헤지거래를 사전적으로 모니터링하기 어렵다. LP가 선물을 이용하여 헤지하더라도 별도의 '헤지계좌' 등록의무가 없으며, 한국거래소 또한 이를 관리하지 않는다⁷⁾. 특히 국내 지수형 ETF의 경우, LP는 거래세 및 대차수수료 부담으로 인해 현물주식 대신 지수선물을 활용한 헤지거래를 주로 수행하고 있으며, 이로 인해 LP 헤지거래의 상당 부분이 감독체계의 사각지대에 놓여 있다. 이러한 구조적 특성으로 인하여 공매도 금지기간 중에도 LP는 '유동성공급 업무에 따른 헤지거래'라는 이유로 차입공매도를 지속할 수 있었으나, 그 인정 범위가 명확하지 않아 백워테이션 국면에서의 특권적 차익거래까지도 정당한 헤지거래로 포섭될 위험이 존재한다.

6) Bloomberg (2016.9.23.) "Kerviel Bill Cut to \$1 Million From \$5.5 Billion by Judges"; BBC News (2012.11.20.), "UBS rogue trader Kweku Adoboli jailed for seven years"; Financial Times, (2011.9.15.) "'Delta One' forced out of the shadows"; 뉴시스 기사 (2024.10.12.) "LP 불법 공매도 사실이었나"...신한투자증권 1300억 손실에 불신 재점화; 인베스트조선 (2024.10.13.) 신한증권 선물매매로 1300억 금융사고...한국판 베어링스 사태?.

7) 한국거래소 관계자 및 증권사 LP 담당자 인터뷰. 실무상 선물 헤지계좌는 별도 등록 대상이 아닌 것으로 확인됨.

본 연구는 이러한 문제의식을 바탕으로 다음 세 가지 목적을 가진다. 먼저, 현행 법령·판례 및 주요국 규제체계를 종합 분석하여 ‘정당한 헤지’와 ‘위법한 투기거래’의 경계선을 제시한다. 그리고 LP가 현실적으로 완전한 100% 헤지를 달성하기 어렵다는 점을 고려하여 ‘합리적 헤지’의 허용범위를 제시함으로써 법적 예측가능성을 제고한다. 마지막으로, 구체적 사례 분석을 통해 유형별 적법성 판단기준을 제시하고, Green Zone(적법)과 Gray Zone(소명 필요)을 구분하여 실무적 가이드라인을 제안한다. 연구방법은 국내 법령·판례 분석과 함께 미국, 캐나다, 유럽 등 주요국의 규제체계를 비교법적으로 검토하는 것이다. 연구의 범위는 국내 주식을 기초자산으로 하는 ETF의 LP 헤지거래를 중심으로 하되, 레버리지·인버스 ETF의 구조적 특성도 함께 고려한다. 나아가 본 연구가 제시하는 원칙은 향후 도입될 가상자산 ETF에도 적용 가능한 이론적 기반을 제공할 수 있다. 이러한 맥락에서, 2024년 미국 증권거래위원회(SEC)의 현물 비트코인 ETF 승인 이후 국내에서도 가상자산 ETF 도입 논의가 본격화되고 있는바⁸⁾, 제도 개선의 시급성은 더욱 커지고 있다.

II. ETF LP 제도와 헤지거래의 구조

1. ETF 유동성공급자(LP)의 역할

(1) LP 제도의 도입 배경

ETF는 펀드임에도 불구하고 거래소에서 주식과 동일한 방식으로 실시간 매매가 이루어지는 특수한 구조를 가진다. 이에 따라 투자자가 언제든지 합리적인 가격에 ETF를 매매할 수 있도록, 시장에서 지속적으로 매수·매도 호가를 제시하는 주체가 필요한데, 이를 유동성공급자(LP)라 한다. 국내에서는 2002년 ETF 제도의 도입과 함께 LP 제도가 정착되기 시작하였다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’) 제

8) SEC(2024.1.10) Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products; 헤럴드경제 기사(2025.8.25.), 가상자산 ETF ‘국정과제’명시...코스피5000 마중물 되나.

234조 제2항 및 같은 법 시행령 제247조는 지정참가회사⁹⁾의 업무로서 “상장지수집합투자기구의 집합투자증권이 증권시장에서 원활하게 거래되도록 하고, 그 가격이 좌수 또는 주수당 순자산가치에 수렴되도록 하는 업무”를 규정한다. 또한 「한국거래소 유가증권시장 업무규정」(이하 ‘거래소 업무규정’) 제20조의2부터 제20조의8까지는 이를 구체화하여, 유동성공급회원의 자격 요건, 의무, 평가 및 제재 절차 등을 상세히 규정하고 있다.

(2) LP의 주요 기능

LP의 규정상 의무와 실무상 역할은 다음과 같다. 첫째, 호가제시 의무이다. LP는 거래 시간 동안 지속적으로 매수·매도 호가를 제시해야 한다. 거래소 업무규정 제20조의4는 최우선평가 기준 호가스프레드비율이 일정 범위를 초과하는 경우, LP가 5분 이내에 유동성공급호가를 제출하도록 규정한다.

호가스프레드비율의 기준은 국내기초자산 2%, 해외기초자산 3% 이내로, 운용사가 거래소에 신고하여 운용된다. 호가스프레드는 매도호가와 매수호가 간의 가격 차이를 의미하며, 호가스프레드비율은 매수호가 대비 스프레드의 비율로 산정된다. 예컨대 매수호가 10,000원, 매도호가 10,050원인 경우 스프레드는 50원, 스프레드비율은 0.5%이다. 실무상 LP는 규정보다 더 엄격한 기준을 적용하며, 통상 운용사와의 계약에서 스프레드비율을 0.5% 이내로 설정한다. 또한 LP가 매도 또는 매수 중 어느 한쪽에 호가를 제출하면, 즉시 반대 방향의 호가를 함께 제시해야 한다¹⁰⁾.

둘째, 괴리율 유지 의무이다. LP는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)에 수렴하도록 관리하여, 괴리율이 일정 수준을 초과하지 않도록 호가를 제출해야 한다. 괴리율은 다음 산식에 따라 산정된다.

$$\text{괴리율} = ((\text{종가} - \text{좌당 NAV}) / \text{좌당 NAV}) \times 100$$

규정상 허용 기준은 국내기초자산 3%, 해외기초자산 6%이다¹¹⁾. LP는 이러한 규제

9) 거래소 규정은 LP가 지정참가회사(AP)일 것을 요구(거래소 업무규정 제20조의2 제2항 제2호 가목).

10) 거래소 업무규정, 제20조의4 제1항 제2호, 제20조의5 제4항.

11) 같은 규정, 제20조의4 제2항.

의무를 이행하는 과정에서 헤지거래를 통해 ETF 가격을 조정하고 수익을 창출하는 실무적 역할을 수행한다. ETF의 시장가격은 기초자산 바스켓의 가치와 일치해야 하지만, 수급 불균형 등으로 인해 NAV와 시장가격 간 괴리가 발생하기 쉽다. LP는 이러한 괴리를 유동성공급 및 헤지거래를 통해 적정 수준으로 회복시키며, 그 과정에서 일정한 수익을 창출한다. 그러나 순수한 헤지거래만으로는 실질적인 수익을 기대하기 어렵다. ETF와 NAV 간 괴리를 이용한 차익거래는 거래비용, 체결 지연에 따른 슬리피지(slippage), 차익거래자 간 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 수익성이 제한적이다¹²⁾¹³⁾. 이러한 한계는 LP로 하여금 정당한 헤지거래로 보기 어려운 백워데이션 갭을 이용한 무위험 차익거래 등 다른 수익원을 적극적으로 모색하게 만드는 구조적 배경이 된다. 문제는 이러한 헤지거래가 어디까지 정당한 리스크 관리에 해당하고, 어디서부터 투기적 차익거래로 평가되어야 하는지에 대한 명확한 법적 기준이 부재하다는 점이다. LP의 헤지거래는 규제상 명문 의무가 아닌 실무적 관행으로 이루어지고 있으며, 바로 이 점이 후술할 법적 쟁점의 핵심이 된다.

2. 헤지거래의 개념 및 필요성

(1) 헤지거래의 기본 개념

‘헤지(hedge)’는 본래 ‘울타리’를 의미하는 단어로, 금융시장에서의 헤지는 자산 가격 변동에 따른 위험을 방어하거나 회피하기 위한 행위를 지칭한다. 자본시장법 시행령은 이러한 헤지 개념을 위험회피 거래로 정의하며, 이를 ‘실제 보유하거나 보유할 자산의 위험을 줄이기 위한 목적으로, 그 자산의 손익 범위 내에서 이루어지는 거래’로 정의하고 있다¹⁴⁾.

12) 류호영·김은총, ETF 가격괴리를 이용한 투자전략: 한국 주식형 ETF를 중심으로, 금융공학연구 제23권 제3호(2024), 64면. 해당 연구에 따르면, ETF 가격괴리를 활용한 투자전략은 당 연하게도 거래비용의 변화에 매우 민감하게 반응하는 것으로 나타났다.

13) 국내 ETF 유동성공급자는 모두 유가증권시장 업무규정 제2조 제24항에 따른 고속알고리즘거래자로 거래소에 등록되어 있는 것으로 확인된다

14) 자본시장법 시행령 제186조의2 제1항 제8호. 같은 법 시행령 제208조의2 제1항 제3호는 유동성공급자의 헤지거래를 "유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래"로 규정한다. 이 규정의 불명확성에 대하여는 III장 2절에서 상술한다.

(2) 헤지거래의 필요성

LP는 ETF 유동성공급 과정에서 필연적으로 ETF 포지션을 보유하게 되며, 이에 따라 가격 변동 위험에 노출된다. 따라서 헤지거래는 LP의 리스크 관리에 필수적이다. 이를 예시로 살펴보면 다음과 같다.

LP가 유동성공급 과정에서 KODEX200 ETF 100만 주를 매수하였다고 가정하자. 현재 ETF 가격이 35,000원이라면, LP는 총 350억 원($35,000\text{원} \times 100\text{만 주}$) 규모의 롱 포지션을 보유하게 된다. 이후 ETF 가격이 34,000원으로 1,000원 하락하면 10억 원의 손실이 발생하고, 반대로 36,000원으로 상승하면 10억 원의 이익이 발생한다. 즉, LP는 ETF를 보유하는 순간부터 시장가격 변동에 따른 위험에 노출되는 것이다. 이러한 위험을 제거하기 위해 LP는 다음 두 가지 대표적인 방법 중 하나를 선택한다

① 기초자산 바스켓 차입공매도 — KOSPI200 지수를 구성하는 삼성전자, SK하이닉스 등 200개 종목을 정확한 비율로 차입하여 공매도하는 방식이다.

② KOSPI200 선물 매도 — 지수선물 계약을 매도함으로써 헤지한다. 이는 기초자산을 직접 거래하는 것보다 거래비용이 낮고, 집행이 신속하다는 장점이 있다¹⁵⁾.

이 두 가지 방법은 모두 ETF 포지션의 가격 변동 위험을 상쇄하기 위한 대표적 수단으로, 거래비용·시장상황·대차 가능 여부 등에 따라 선택된다.

(3) ETF 헤지의 기본 원리

ETF LP 헤지의 기본 원리는 다음의 등식에 기초한다.

ETF 시장가격 $\approx$ 순자산가치(NAV) = 기초자산 바스켓 가치

예컨대 KODEX200 ETF 1주는 KOSPI200 지수를 구성하는 200개 종목을 동일 비율로 보유한 포트폴리오와 동일한 경제적 가치를 가진다. 따라서 LP가 ETF를 매수한 경우(지수 상승 시 이익, 하락 시 손실), 지수 하락에 따른 손실 위험을 상쇄하기 위해 기초자산 바스켓 또는 KOSPI200 선물을 매도함으로써(지수 하락 시 이익, 상승 시 손실)

15) 그 외에도 장외파생상품 거래나 ETF 차입공매도 등 다양한 헤지 방식이 활용될 수 있으며, ETF를 매도한 경우에는 이에 대응하여 지수선물 또는 기초자산을 매수하는 방식으로 시장 위험을 제거한다.

포지션을 중립화한다. 이론적으로 두 포지션의 손익은 상쇄되어, 지수 변동에 따른 가격 위험이 제거된다. 다만, 실무적으로는 ETF 시장가격과 순자산가치(NAV) 간의 괴리율, 선물 베이스(basis) 변동, 거래비용 등의 요인으로 인해 완전한(100%) 헤지를 달성하기는 어렵다.

3. ELS 헤지거래와 비교(선형성 vs 비선형성)

ETF는 ELS에 비해 선형성(linearity)이 높은 금융상품이다. 예컨대 KOSPI200 지수가 1% 변동하면 KODEX200 ETF도 대체로 1% 내외로 변동하며(괴리율을 제외할 경우), 델타(Δ)가 1에 근접하므로 헤지비율 산정이 상대적으로 단순하다. 반면, ELS는 구조적으로 비선형(non-linear) 특성을 가지므로 헤지 계산이 복잡하다. 특히 배리어 옵션 구조의 ELS는 기초자산 가격이 배리어 근처에 위치할 때 델타값이 급격히 변동하며, 만기 시점에는 델타가 무한대로 발산하거나 0으로 수렴하는 등 불안정성이 심화된다¹⁶⁾. 이러한 구조적 차이는 ETF LP 헤지거래 규율에 다음과 같은 함의를 갖는다. ELS는 비선형 구조로 인해 델타값의 변동성이 극단적이므로, 정량적 기준을 일률적으로 적용하기 어렵다. 반면 ETF는 선형성이 높아, 정당한 헤지거래의 수량적 기준을 명확히 설정할 수 있다는 점에서 규율 가능성이 높다. 따라서 본 논문은 ELS 델타헤지 관련 판례에서 제시된 법리를 하나의 비교 기준으로 삼아, 선형성이 높은 ETF LP 헤지거래에 적용 가능한 정당한 헤지 판단기준을 도출하고 그 적용 가능성을 제시하고자 한다.

4. LP 헤지거래의 시장 영향

LP의 헤지거래는 ETF 가격을 순자산가치(NAV)에 수렴시킴으로써 시장 효율성을 제고하고 유동성을 공급하는 거래로 이해되어 왔으며, ETF를 매도·매수하는 개별 투자자

16) 김주영, "헤지거래기법을 이용한 투기거래와 이에 대한 법적 규제", 증권법연구 제12권 제3호, 2011, 204-207면; 김흥기, "ELS 델타헤지의 정당성과 시세조종에 관한 연구 - 대법원 2016. 3. 24. 선고 2013다2740 판결을 대상으로 -", 상사판례연구 제29집 제2권, 2016, 92-98면; 나지수, 2016, 추가연계증권(ELS) 델타헤지거래 관련 분쟁의 분석, 증권법연구, 제17권 제1호, 118-119면; 이에 따르면 ELS 발행사는 "델타값이 급변하여 정확한 헤지가 어렵다"는 항변을 할 수 있으나, ETF LP는 선형성으로 인해 이러한 항변이 제한될 것이다.

에게 직접적인 손해를 야기하지 않는 것으로 인식되어 왔다.

그러나 일부 실증 연구는 이러한 일반적 이해와 달리, 과도한 LP 헤지거래가 기초자산의 변동성을 확대시키고 개별 투자자에게 실질적인 손해를 초래할 수 있음을 보여준다¹⁷⁾. 송준혁·이창일(2020)은 199개 ETF를 대상으로 한 분석에서, ETF 보유 증가가 개별 주식의 호가스프레드 확대, 거래비용 증가 및 체계적 위험 상승 등 부정적 효과를 유발함을 확인하였다¹⁸⁾. 한국자본시장연구원(2023) 역시 패널 회귀분석을 통해 ETF 보유비중이 1% 증가할 경우 개별 주식의 시장 변동성이 0.051%포인트 증가함을 실증하였다¹⁹⁾. 삼성증권(2022)은 ETF 편입이 KOSPI200 구성종목에 미치는 영향을 검토한 결과, ETF 설정으로 유통 가능 물량이 감소하면서 가격민감도가 상승하였고(예: 포스코케미칼 편입비중 9.58%), ETF 편입비중 증가는 대차잔고 확대를 통해 공매도 및 차익거래 활용도를 제고하는 효과를 가져온 것으로 분석하였다. 또한 지수 구성 변경 시 대량 매매가 집중됨으로써 상당한 수급 충격이 발생하였으며(예: LG에너지솔루션 편입 시 약 5,000억 원 규모), 특히 유동성이 낮은 중형주일수록 LP 헤지거래로 인한 가격 충격이 더 크게 나타날 수 있음을 확인하였다²⁰⁾.

이상의 실증 결과는 ETF 편입비중이 높아질수록 LP 헤지거래의 시장 영향이 확대될 수 있음을 시사하며, “헤지거래는 차익거래이므로 손해를 입는 주체가 존재하지 않는다”는 종래의 인식에 의문을 제기한다. 따라서 LP 헤지거래는 차익거래라는 이유만으로 무제한 허용될 수 없으며, 거래 목적과 위험 노출 범위에 비례한 적정 수준 내에서 허용될 필요가 있다.

-
- 17) Malamud, S. (2016), ‘A Dynamic Equilibrium Model of ETFs,’ Working Paper, Swiss Finance Institute; Bhattacharya, A. and M. O’Hara (2016), ‘Can ETFs Increase Market Fragility? Effect of Information Linkages in ETF Markets,’ Working Paper, Cornell University, 김세환·김민주·김영민, (2024), ETF 지분이 기초자산 주식의 변동성에 미치는 영향 분석, 금융공학연구, 제23권 제2호, 63면에서 재인용. 위 연구에 따르면 차익거래 과정에서 대량의 기초자산이 단기간에 집중 거래되면서, 개별 종목이 펀더멘털과 무관하게 ETF 가격조정을 위한 수단으로 이용되어 가격 변동성이 확대되는 것으로 분석된다. 이를 ETF LP 헤지거래의 맥락에서 단순화하면, 투자자의 ETF 매도 → ETF 시장가격 하락(NAV 대비 할인) → LP의 ETF 매수(유동성 공급) → 매수 포지션의 위험 상쇄를 위한 기초자산 차입공매도 → 기초자산 가격 하방 압력의 경로로 정리할 수 있으며, 이 과정이 반복·집중될수록 기초자산의 변동성 확대 및 가격 충격이 심화될 수 있다.
- 18) 송준혁·이창일, "ETF 시장 확대가 개별 구성 주식의 행태에 미치는 효과 분석", 선물연구 제28권 제1호 (2020), 63면, 97면.
- 19) 김민기·김준석, ETF가 주식시장에 미치는 영향, 자본시장연구원 연구보고서 23-03, 2023, 41면, 61-63면
- 20) 삼성증권, 글로벌투자전략팀 전균(2022.3.25.), ETF가 개별종목에 미치는 영향: KOSPI200 구성종목에 대한 ETF 편입비중 추적, Derivatives Spot, 13면, 18면.

5. 차익거래와 정당한 헤지거래의 외형적 구별

이론적으로는 두 개념이 명확히 구별된다. 헤지거래(hedging)는 보유 포지션의 위험을 상쇄하여 손실 가능성을 줄이는 것을 주된 목적으로 하는 반면, 차익거래(arbitrage)는 가격 불균형을 이용해 무위험 또는 저위험 수익을 추구하는 거래를 의미한다. 그러나 외형적으로는 이 두 거래가 명확히 분리되지 않는다.

LP는 ETF 유동성공급 과정에서 필연적으로 차익거래 기회에 노출되며, 헤지 수단으로 선물을 활용하는 경우 베이스 차익이 불가피하게 수반된다. 또한 ETF와 순자산가치(NAV) 간 괴리를 해소하는 과정 자체가 차익거래적 성격을 내포하고 있다. 나아가 ETF와 기초주식 간, 현물과 선물 간 등 경제적으로 연동된 금융상품 사이의 가격차이는 LP가 헤지 포지션과 차익 포지션을 동시에 보유하게 되는 구조적 요인으로 작용한다. 이러한 가격차이는 단기적으로 수렴하거나 확산함에 따라, 헤지 목적의 거래라 하더라도 결과적으로 손익이 발생할 수밖에 없다. 결국 위험회피를 목적으로 한 헤지거래에서 발생한 손익조차, 외형상으로는 가격 불균형을 이용한 차익거래의 결과와 구별하기 어렵다. 즉, LP는 유동성공급 과정에서 복수의 목적 — 위험 제거(헤지), 스프레드 수익(시장조성), 베이스 차익(결과적 수익) — 을 동시에 추구하게 된다. 따라서 헤지거래와 차익거래는 외형상 동일한 거래 형태로 나타날 수 있으며, 정당한 헤지거래의 범위를 명확히 한정하기 어려운 구조적 한계가 내재되어 있다.

그러나 외형적 중첩이 존재한다는 사실이 법적 규율 자체를 불가능하게 만드는 것은 아니다. 오히려 이러한 구조적 복잡성이야말로 명확한 법적 기준의 필요성을 보여준다. 예컨대, ETF 유동성 공급 활동이 미미하거나 부재함에도 불구하고 대규모 헤지거래만을 수행하는 경우(대상성 결여) 해당 거래는 정당한 헤지거래로 볼 수 없다. 마찬가지로 ETF 롱 포지션 100억 원에 대해 선물 200억 원을 매도하는 등 유동성 공급 규모에 비해 명백히 과도한 헤지 포지션을 보유하는 경우(비례성 이탈) 역시 정당성이 부인된다. 반면 ETF 포지션 100억 원에 대해 선물 100억 원을 헤지하는 과정에서 베이스 차익 5천만 원이 발생하는 것은, 정당한 헤지거래에서 부수적 차익이 발생한 것으로 볼 수 있다. 그러나 현행 법제는 이러한 실체적 기준을 제시하지 못하고 있다. 다음 장에서는 국내 법령과 판례를 검토하여 이러한 법적 공백의 구체적 양상과, 그로 인한 감독 체계의 한계를 분석한다.

III. 국내 법제의 현황과 한계

1. ETF LP 제도의 규제 편익

LP는 ETF 시장에서 유동성 공급 및 가격안정 기능을 담당하는 공적 주체로서, 이에 따라 일반 투자자와는 구별되는 일정한 규제상 편익을 부여받는다.

(1) 공매도 가격규제의 예외

자본시장법 제180조 제1항은 원칙적으로 공매도를 금지하되, 차입공매도의 경우 “대통령령으로 정하는 방법에 따르는 경우”에 한하여 이를 허용한다. 같은 법 시행령 제208조 제2항은 이를 구체화하여, 차입공매도는 “증권시장업무규정에서 정하는 가격”으로 이루어져야 한다고 규정한다. 거래소 업무규정 제18조 제1항은 이러한 ‘가격’을 명시하며, 차입공매도 시 직전 거래가격 이하로 호가할 수 없도록 규정하고 있다. 이른바 업틱룰(uptick rule) 이다. 그러나 LP에 대해서는 이러한 가격규제가 예외적으로 면제된다²¹⁾. 2018년 6월부터 9월까지의 거래 통계에 따르면, 매도 헤지거래는 전체 시장 당일 거래대금의 평균 2.31%를 차지하였으며, 매도 차익거래 또는 헤지거래(ELW, ETN 등 포함)가 발생한 종목·일을 기준으로 계산할 경우, 매도 헤지거래 중 공매도 방식으로 제출된 매도 호가의 비중은 평균 62.33%에 달했다²²⁾. 이는 업틱룰 예외 규정이 실무상 광범위하게 활용되고 있음을 보여준다. 이러한 예외는 LP가 ETF 포지션의 위험을 신속히 제거해야 한다는 점에서 합리적 근거를 가지지만, 남용될 경우 일반투자자와의 형평성 문제가 발생할 수 있다.

21) 거래소 업무규정 제18조 제1항 및 제2항.

22) 우민철·김지현, 공매도를 이용한 불공정거래 개연성, 한국증권학회지 제48권 제1호(2019), 122-123면. 다만, 2020년 공매도 금지 기간 중 형평성 논란이 제기되면서 주식 LP 및 MM(Market Maker)의 업틱룰 예외가 폐지되어, 해당 비율은 감소했을 것으로 추정된다. 이에 대해서는 금융위원회 보도자료(2020. 12. 28.), 「공매도 제도 개선방안」 참조.

(2) 공매도 전면금지시 헤지 목적 차입공매도 예외

자본시장법 제180조 제3항은 금융위원회가 증권시장 안정을 위하여 공매도를 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 이에 따라 금융위원회는 2023년 11월 전 종목에 대한 차입공매도 전면 금지 조치를 시행하였다. 다만, ETF LP의 헤지 목적 거래 등 시장안정을 저해하지 않는 유형(ETN·ELW LP 헤지거래 포함)에 대해서는 예외를 인정하였다²³⁾²⁴⁾. 이러한 특혜는 LP가 진정한 헤지 목적으로만 공매도를 수행한다는 전제하에서만 정당화될 수 있다. 그러나 공매도 금지로 인해 일반투자자의 숏포지션이 제한되면서 시장의 구조적 불균형이 발생하였다. 일반투자자는 공매도가 금지되어 주가 하락에 베팅할 수단이 선물시장 매도로 제한되었고, 이에 따라 선물가격이 현물가격보다 낮아지는 백워데이션 현상이 지속되었다²⁵⁾²⁶⁾. 정상적인 시장에서는 차익거래자가 ‘선물 매수-현물 차입공매도’를 통해 가격피리를 해소할 수 있으나, 공매도 금지로 인해 이러한 거래가 불가능해졌다. 반면, LP는 ‘헤지 목적’ 예외를 근거로 현물 차입공매도가 가능하였고, 이는 결과적으로 LP에게만 차익거래 기회를 제공할 수 있는 환경을 조성하였다. 예를 들어, LP가 ETF 유동성공급 없이 주식선물을 98,700원에 매수하고 동시에 A전자 주식을 100,000원에 차입공매도하면, 초기 단계에서 1,300원의 베이스스 차익이 발생한다. 주식선물의 최종결제가격은 만기일 기초주권의 증가로 확정되므로²⁷⁾, 만기 시 선물은 현

23) 금융위원회 보도자료(2023.11. 5.), 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고, 전향적인 공매도 제도개선을 추진합니다; 금융위원회 보도참고자료(2024.6.13.), 공매도 금지 조치를 '25.3.30일(일)까지 연장합니다.

24) 거래소 통계에 따르면 2023.11.06. ~ 2024.12.30. 까지 공매도 금지기간 동안의 차입공매도 거래대금은 대부분 ETF 유동성공급자의 거래에서 발생한 것으로 나타났다(KRX정보데이터시스템 참조).

구분	ETF LP	ETN LP	ELW LP	파생 MM
KOSPI	103,389억원	0.1억원	0.06억원	48억원
KOSDAQ	53,185억원	0.1억원	0.2억원	0.9억원

25) 아시아경제(2023.11.24.), 공매도 금지하자 외국인 선물 매도 늘어; 더벨(2023.12.11.) [공매도 금지 후폭풍]선물 숏 증가...백워데이션·블록딜 이상 현상.

26) 포스코퓨처엠 개별주식 선물의 일별 자료를 한국거래소 정보데이터시스템에서 추출하였으며, 공매도 금지 시행일(2023.11.6.)을 기준으로 금지 전 10개월('23.1~'23.11.3, 401일 관찰치)과 금지 후 10개월('23.11.6 ~ '24.8, 391일 관찰치)로 구분하여 총 792일 관찰치를 분석하였다. 개별주식선물은 복수의 만기월물이 동시에 거래되므로, 관찰치 수는 고유 거래일 수를 상회한다.

구분	백워데이션 비율	평균 시장 베이스스
금지 전('23.1~'11.3)	19%(78/401)	+ 409.726 원
금지 후('23.11.6~'24.8)	67%(263/391)	- 1,078.517 원

27) 한국거래소, 파생상품시장업무규정 세칙(주식선물시장업무세칙) 제11조 제3항(2014.8.28. 신설)

물 증가 가격으로 현금결제되고, LP는 이에 맞추어 현물을 매수하여 기존의 차입공매도 포지션을 청산한다. 이 과정에서 초기 베이스스 1,300원은 규정상 확정된 차익으로 실현된다²⁸⁾. 주식선물 1계약은 ‘주가 × 10주’ 단위로 구성되므로, 10,000계약 거래 시 약 1억 3천만 원의 수익이 발생한다. 이는 일반투자자가 접근할 수 없는, LP만이 누릴 수 있는 특권적 차익거래 기회이다.²⁹⁾

(3) 순보유잔고 보고의무의 예외

자본시장법 시행령 제208조의2 제3호는 유동성공급 또는 시장조성 과정에서 발생하는 경제적 손실을 줄이기 위한 헤지거래에 대하여 순보유잔고 보고의무를 면제하고 있다. 이 제도는 2012년, “증권시장의 안정성과 공정한 가격형성에 영향을 미칠 수 있는” 대규모 공매도 포지션을 감독하기 위한 목적으로 도입된 것이다. 따라서 LP의 공매도 포지션이 크더라도 그 거래가 정당한 헤지거래에 해당한다면 보고의무를 면제하는 것은 합리적이다. 그러나 ‘정당한 헤지’의 판단기준이 명확히 확립되지 않은 상태에서 투기적 거래가 헤지 명목으로 보고의무를 회피하게 될 경우, 이는 제도의 입법취지에 반하는 결과를 초래할 수 있다³⁰⁾.

2. 헤지거래 관련 규정의 체계적 불명확성

(1) 현행 체계의 문제

(가) 자본시장법

28) 계산: 1,300원 × 10주 × 10,000계약 = 130,000,000원. 구체적으로, 만기일 현물 증가가 X 원일 때 (1) 선물 청산 손익: X - 98,700 (2) 현물 매수·상환 손익: 100,000 - X (3) 합계: 1,300원 확정

29) 차입비용 급등, 대주의 주식 회수(리콜), 시장 급변동 시 유동성 위험 등은 남아있다.

30) 자본시장법 제180조의2 제1항, 같은 법 시행령 제208조의2 제1항 제3호. 개정 이유에 따르면, “증권시장의 침체 시 시장교란 요인이 되는 공매도의 역기능을 방지하고, 최근 주요 해외 금융 선진국이 공매도 거래에 대한 보고제도를 도입하는 추세를 고려하여, 주식 등을 공매도한 자의 순보유잔고가 증권시장의 안정성과 공정한 가격형성에 영향을 미칠 수 있는 기준에 해당하는 경우, 그 매도자 및 순보유잔고 등에 관한 정보를 금융위원회와 한국거래소에 보고하도록 하기 위함”이라고 명시하고 있다.

자본시장법은 ‘헤지(hedge)’라는 용어 대신 ‘위험회피’라는 표현을 사용하고 있다. 동법 제166조는 금융투자업자가 일반투자자를 상대로 장외파생상품 거래를 하는 것을 원칙적으로 금지하면서도, “위험회피 목적의 거래”는 예외로 인정한다. 또한 제288조의2는 장외파생상품심의위원회가 “위험회피 구조의 타당성”을 심의하도록 규정한다. 그러나 ‘위험회피’의 개념이나 그 요건이 명확히 정의되어 있지는 않다.

(나) 자본시장법 시행령

자본시장법 시행령 제186조의2는 장외파생상품 거래에서의 “위험회피 목적 거래”를 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”로 정의하면서, 그 요건으로 “손익의 범위를 초과하지 아니할 것”이라는 비례성 요건을 명시하고 있다. 반면, 동 시행령 제208조의2는 LP의 순보유잔고 금지 예외를 규정하면서도 비례성 요건을 포함하지 않는다. 이로 인해 LP의 헤지거래에 관하여는 비례성 요건의 적용 여부 및 판단 기준이 법령상 명확하지 않다³¹⁾.

(다) 한국거래소 규정

거래소 업무규정 제18조 제2항 제7호는 업틱룰 예외로서 “유동성공급호가를 제출하는 회원이 매수한 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 가격변동에 따른 손실을 회피하거나 줄이기 위하여 기초주권을 매도하는 경우”를 규정한다. 그러나 해당 조항은 ① 일방향 헤지(ETF 매수 → 기초주권 매도)만을 명시하고, ② 헤지 수단을 “기초주권”으로 한정하며, ③ 헤지 규모의 상한 또는 비례성 기준을 제시하지 않는다. 따라서 이를 근거로 정당한 헤지거래의 범위를 규정했다고 보기는 어렵다.

31) 이는 규제 구조 차이를 반영한 것으로 추정된다. 제186조의2는 거래 금지의 예외 허용(제166조)이므로 “손익의 범위”라는 명확한 한계가 필요하고, 일반투자자 보호를 위해 엄격한 기준을 요한다. 제208조의2는 의무의 면제(제180조의2)이므로 개념적 요건만 제시한 것으로 추정된다. 다만 입법 자료 검토 결과 이러한 의도를 명시한 자료는 발견되지 않아, 의도적 차별화인지 입법 미비인지는 불명확하다.

(2) 자본시장법 시행령 제208조의2의 세부 검토

자본시장법 제180조의2는 순보유잔고 보고의무를 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제208조의2 제1항은 그 예외 대상 거래를 구체적으로 정하고 있다. 시행령 제208조의2는 LP³²⁾의 헤지거래를 순보유잔고 보고의무에서 면제하고 있으나, 정당한 헤지거래가 무엇인지에 대한 명확한 법적 기준이 없어 다음과 같은 문제점이 존재한다.

(가) 헤지 규모에 대한 비례성 요건 부재

시행령 제186조의2는 장외파생상품 거래의 예외 요건으로 “손익의 범위를 초과하지 아니할 것”이라는 비례성 원칙을 명시하고 있으나, 제208조의2 제3호는 LP의 순보유잔고 보고의무 예외를 규정하면서도 비례성 기준을 포함하지 않는다. 양 조문 모두 특정 제도의 예외 요건을 정한 것에 불과하며, 정당한 헤지거래 자체를 규율하려는 입법취지를 가진 조문은 아니다.

그러나 제208조의2는 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”라는 포괄적 문구를 사용할 뿐, 어느 정도의 손실 감소가 “위험회피”로 인정될 수 있는지에 대한 판단기준을 제시하지 않는다. 이로 인해 LP가 ETF 포지션의 50%만 헤지하거나 150%를 과잉헤지하더라도 모두 “부분적 또는 전체적으로 손실을 줄이기 위한 거래”로 해석될 여지가 있으며, 실질적으로 대부분의 공매도를 '헤지 목적'으로 주장할 수 있는 법적 공백이 존재한다. 결과적으로 ETF LP가 직접 적용받는 제208조의2에는 비례성 요건이 부재한 반면, 장외파생상품 규제인 제186조의2에는 이를 포함하고 있어, 자본시장법 체계상 불명확성이 존재한다.

32) 동 조항은 ETF LP를 포함하여 주식·ELW·ETN 유동성공급자 및 파생상품의 시장조성자 전반에 적용되나, 본 논문에서는 논의의 편의상 ETF LP에 한정하여 검토한다.

(나) 기타 조문 해석상 문제

제208조의2(순보유잔고의 보고) ① 법 제180조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 2. 증권시장업무규정 및 법 제393조제2항에 따른 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성을 위한 상장주권의 거래 3. 제2호에 따른 유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래

제208조의2 제3호는 순보유잔고 보고의무의 예외 대상을 “제2호에 따른 유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래”로 규정하고 있다. 즉, 제2호의 요건을 전제로 한 예외 구조를 취한다. 그런데 제2호는 “증권시장업무규정 및 법 제393조 제2항에 따른 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성공급 및 시장조성을 위한 상장주권의 거래”로 규정하고 있다. 이 조문은 두 가지 방식으로 해석될 수 있다.

① ‘(유동성공급 및 시장조성)을 위한 상장주권의 거래’로 해석할 경우, 유동성공급 역시 “상장주권의 거래”여야 한다. 그러나 ETF는 상장주권이 아니라 집합투자증권³³⁾이므로, 제2호의 적용대상에 포함되지 않으며, 이에 따라 제3호의 헤지거래 예외 또한 적용될 수 없다.

② 반면 ‘유동성공급 및 (시장조성을 위한 상장주권의 거래)’로 해석할 경우, 유동성공급은 거래대상 증권의 종류를 불문하고 인정되며, 시장조성만이 상장주권으로 한정된다. 이 경우 ETF 유동성공급 역시 제2호에 포함되어 제3호의 헤지거래 예외를 적용받을 수 있다.

문제는 조문 문언만으로 어느 해석이 타당한지를 명확히 단정하기 어렵다는 점이다. 실무상 LP가 헤지 목적으로 기초자산(상장주권)을 공매도하는 경우 순보유잔고 보고를 하지 않고 있는 것으로 파악된다. 그러나 ①의 해석을 전제로 할 경우, ETF 유동성공급은 “상장주권의 거래”가 아니므로 제2호의 적용대상에서 제외되고, 결과적으로 제3호의 헤지거래 예외도 적용될 수 없게 된다. 이러한 해석에 따르면, LP가 헤지 목적상 기초자산을 공매도하더라도 순보유잔고 보고의무의 예외를 인정받을 수 없게 되어 실무운용 및 입법취지와 조화되지 않는다³⁴⁾. 따라서 해당 조문의 적용범위와 해석기준을 명확히

33) 투자신탁 형태의 ETF는 수익증권으로 발행되는데, 2023년 말 기준 국내 ETF는 전부 투자신탁형으로만 출시되어 있다. 한국예탁결제원, ETF 설정환매 업무안내 (2024), 5-8면 참조.

할 필요가 있다.

(3) 제재 규정의 해석

자본시장법 제180조 제3항은 금융위원회로 하여금 증권시장의 안정성 및 공정한 가격형성을 저해할 우려가 있는 경우, 거래소의 요청에 따라 차입공매도를 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 문제는 금융위원회가 동조 제3항에 근거하여 공매도를 제한한 상황에서, ETF 유동성공급자(LP)의 거래가 헤지거래 예외의 요건을 충족하지 못하는 것으로 평가되는 경우 과징금 부과가 가능한지 여부이다.

이에 대하여 부정설은 제3항이 금융위원회에 행정권한을 부여하는 수권규정일 뿐, 시장참여자에게 직접적인 행위의무를 부과하는 금지규범은 아니라는 점을 근거로 들 수 있다. 제재규정은 엄격해석되어야 하므로, 제3항 위반만으로 과징금을 부과하는 것은 허용될 수 없다는 입장이다³⁵⁾.

그러나 이에 대한 긍정설이 타당하다. 먼저, 입법취지에 비추어 볼 때, 제180조 제3항과 제429조의3이 2021년 1월 5일 동시에 개정된 것은 공매도 규제의 실효성을 제고하려는 동일한 입법목적에 달성하기 위한 일련의 조치이다³⁶⁾. 특히 제3항이 시행령에서 법률로 상향되고, 동시에 과징금 제도가 신설된 점은 입법자가 제3항에 따른 제한 조치의 위반행위 역시 제재 대상으로 포섭하려는 명시적 의사가 있다고 해석할 수 있다³⁷⁾. 둘째, 체계적 해석의 관점에서도 같은 결론에 이른다. 제429조의3 제1항이 “제180조를 위반한 자”라고 규정한 이상, 이는 특정 항을 한정하지 않고 조문 전체를 포괄하는 문언

34) 나아가 해당 조문에 ETF LP의 거래가 포섭되지 않는다면, 금융투자업규정상 ‘공매도’ 판단 기준 자체를 재검토해야 한다. 같은 규정 제6-30조 제6항은 영 제208조의2 제1항 제2호 및 제3호에 따른 거래의 경우, 계좌별·재산별로 공매도 여부를 판단하도록 규정하고 있다.

35) 대법원은 “침익적 행정처분의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고, 행정처분의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하여서는 아니 되며, 그 행정법규의 입법 취지와 목적 등을 고려한 목적론적 해석이 허용되는 경우에도 그 문언의 통상적인 의미를 벗어나지 아니하여야 한다.”고 판시했다(대법원 2016.11. 24. 선고 2014두47686 판결).

36) 금융위원회 보도자료(2020.12.28.), “공매도 제도 개선방안”; 같은 취지로 국회 정무위원회, 자본시장법 일부개정법률안 검토보고서 (2020. 12.).

37) 2021년 개정을 통해 제180조 제3항의 차입공매도 제한 조치 내용이 시행령에서 법률로 상향되었으며, 이와 함께 제429조의3(과징금)이 동시 신설된 것은 제3항 위반에 대한 제재 의도로 해석된다. 개정이유 참조 “공매도에 대한 관리를 보다 엄격히 함으로써 시장의 신뢰성을 제고하려는 것”이라고 명시한다. 법률 제17879호 (2021. 1. 5. 일부개정).

이다. 제180조 제2항의 예외 요건을 주장하였으나, 요건을 충족하지 못한 경우가 제180조 위반으로 제재되는 것과 마찬가지로, 제3항에 따른 제한 명령을 위반한 경우 또한 그 포섭 대상에 포함된다고 보아야 한다³⁸⁾. 셋째, 규제 실효성의 관점에서도 긍정설의 해석이 타당하다. 제3항 위반에 대한 제재수단이 결여된다면, 금융위원회 제한조치는 실효성을 확보할 수 없을 것이다.

다만, 이러한 긍정설에도 불구하고 현행 규정은 여전히 구조적 한계를 지닌다. 정당한 헤지거래와 위법한 투기거래를 구분할 객관적 기준이 부재한 상황에서, LP는 자신의 거래가 제재대상에 해당하는지 사전에 예측하기 어렵다. 이는 제재 근거 규정이 명확성 원칙에 반할 소지가 있다. 따라서 정당한 헤지의 판단기준이 명문화되지 않는 한, 이러한 문제는 지속될 것이다.

3. 관련 판례 검토

ETF LP 헤지거래의 정당성을 직접 다룬 판례는 없는 것으로 확인된다. 따라서 환헤지, 통화옵션(KIKO), 추가연계증권(ELS) 판례에서 확립된 헤지거래 법리를 검토하여 ETF LP에 적용 가능한지 살펴본다. 다만 환헤지·ETF는 선형, KIKO/ELS³⁹⁾는 비선형 상품이라는 구조적 차이가 존재하므로, 각 판례에서 제시된 기준은 해당 금융상품의 특성을 고려하여 제한적으로 원용될 필요가 있다.

(1) 정당한 헤지거래의 요건 - 대법원 2005두12824 판결 (환헤지)

대법원 2006. 2. 10. 선고 2005두12824 판결은 환헤지 거래와 관련된 조세 사건이나, 정당한 헤지거래의 본질적 요건을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 이 사건에서 원고 제조업체는 원료를 수입하면서 환율 변동으로 인한 손실을 방지하기 위해 외화 선도거래

38) 제180조 제2항 및 동법 시행령 제208조 제3항은 공매도의 예외를 규정하는데, LP가 그 요건을 충족하지 못하면서 예외에 해당한다고 주장할 경우 "제180조 위반"으로 제재 가능한 것과 같은 논리다.

39) ELS는 발행사가 헤지거래 과정에서(예외 백투백 헤지) 조기상환 회피를 통한 수익 극대화 유인과 투자자의 조기상환 기대 간에 이해상충이 존재한다(대법원 2013다3811참조). 반면 ETF LP는 이러한 구조적 이해상충이 존재하지 않는 점에서 차이가 있다.

를 체결하였고, 과세관청은 이 거래에서 발생한 소득이 중소기업특별세액감면 대상인 '당해 사업에서 발생한 소득'에 해당하지 않는다고 보아 경정처분을 하였다.

대법원은 "환투기의 목적 없이 오로지 원료 수입대금의 결제와 관련하여 환차손으로 인한 영업상 손실을 방지하기 위하여 외화 선도거래에 의한 헷지거래를 하였다면, 그 헷지거래는 그 중소기업이 영위하는 제조업을 효율적·안정적으로 운영하기 위하여 필수적으로 요구되는 영업활동"으로서 정당한 헤지거래에 해당한다고 판시하였다. 이 판결로부터 정당한 헤지거래의 요건을 다음과 같이 정리할 수 있다. 먼저, 헤지 대상이 명확히 존재해야 한다. "원료 수입대금 결제와 관련하여"라는 표현에서 확인되듯, 헤지 대상이 특정되고 실재해야 한다. 둘째, 위험회피 목적이 인정되어야 한다. "환차손으로 인한 손실을 방지하기 위하여"라는 적극적 목적과 함께 "환투기의 목적이 없이"라는 소극적 요건도 충족해야 한다. 셋째, 헤지 수단이 적정해야 한다. 외화 선도거래가 환위험 헤지를 위한 "필수적" 수단이어야 한다는 점에서, 헤지 규모와 방법이 대상 위험과 비례해야 함을 시사한다.

이 판결은 비록 환헤지 사안이나, ①헤지 대상의 존재(대상성), ②위험회피 목적(목적성), ③수단의 적정성(비례성)이라는 요건은 금융상품의 종류를 불문하고 적용될 수 있는 일반 법리로 볼 수 있다. 특히 환헤지는 환율 변동과 선도계약 가치가 1:1로 연동되는 선형 상품으로, ETF 역시 기초지수와 선형 관계에 있다는 점에서 이 판례의 법리는 ETF LP 헤지거래에 직접 적용할 수 있을 것이다.

따라서 ETF LP가 유동성 공급 과정에서 보유하게 된 ETF 포지션(대상성)을 가격 변동 위험으로부터 보호하기 위해(목적성) 합리적 범위 내에서(비례성) 기초자산 또는 선물을 거래한다면, 이는 정당한 헤지로 인정될 수 있다.

(2) 헤지 대상의 현저한 초과와 투기성 판단 - 대법원 2013다26746 (KIKO 사건)

대법원 2013. 9. 26. 선고 2013다26746 전원합의체 판결은 헤지 범위의 적정성(비례성)에 관한 중요한 법리를 제시하였다. 이 사건에서 수출기업의 월평균 달러 매출액은 약 160만 달러였으나, 피고 은행과 체결한 통화옵션 계약금액은 270만 달러로 약 1.7배에 달하였고, 다른 은행과의 계약까지 합치면 월 950만 달러, 즉 약 6배 수준에 이르렀다. 대법원은 "적정한 헤지비율이 유지되는 한 이 사건 각 통화옵션계약에 따른 손익 여

부만을 놓고 원고의 전체적인 손익을 평가하여서는 아니 된다"고 전제한 후, 만약“오버 헤지(over-hedge)가 되는 경우에는 현실적인 손실이 발생하지만, 통화옵션계약은 기초자산 없이 투기 목적으로도 이용될 수 있고, 기초자산이 없이 환차익을 얻을 목적으로 통화옵션계약을 체결하였다면 그에 따른 위험이 발생하는 것은 당연하므로 원고에게 현실적인 손해가 발생하였다고 하여 이 사건 각 통화옵션계약의 효력을 유지하는 것이 신의칙에 반한다고 할 수 없다"고 판시하였다.

대법원은 ①예상 외화유입액을 현저히 초과하는 계약금액, ②이미 over-hedge 상태에서의 추가 계약 체결, ③단기간(6개월) 내 5개 은행과 15건의 계약 체결, ④환율 하락 전망 하에서 일시적 상승기에 계약 체결, ⑤환차익 추구 정황 등 복수의 요소를 종합적으로 고려하여, 해당 거래가 환헤지 목적이 아닌 환투기적 거래로 평가된다고 보았다⁴⁰⁾. 이 판결은 ‘헤지 대상 범위를 현저히 초과하는 거래는, 다른 정황과 종합할 때 투기적 목적이 인정될 수 있다’는 원칙을 확인한 것으로 평가된다. 다만 대법원이 구체적 수치 기준(몇 배 또는 몇 퍼센트부터가 과다헤지인가)을 제시한 것은 아니며, 1.7배 또는 6배라는 수치는 투기 목적 판단을 위한 여러 정황 중 하나로 참작되었다. 이를 ETF LP 헤지거래에 적용할 경우, 헤지비율이 보유 포지션을 현저히 초과하는 경우는 그 자체로 투기성을 단정할 수는 없지만, 다른 정황과 결합될 때 투기 목적의 거래로 평가될 가능성이 높다는 점을 시사한다.

이 판례는 헤지 대상(월 160만 달러)의 1.7배 계약을 과다하다고 판단하였으나, 그렇다고 해서 100-170% 사이의 모든 구간이 허용되는 것은 아니다. 대법원은 “적정한 헤지비율”이라는 표현을 사용함으로써, 헤지 대상을 초과하는 계약도 일정 범위 내에서는 정당화될 수 있음을 시사하였다. 다만 본 판례는 통화옵션이라는 비선형 구조의 파생상품에 관한 것이므로, 선형 구조의 ETF에 직접 적용하는 건 신중해야 한다. 중요한 것은 ‘현저한 초과’가 투기로 추정된다는 원칙이며, ‘현저한’의 구체적 기준은 상품의 특성과 시장 관행을 고려하여 정해져야 한다.

40) 이러한 사정들을 종합하면, 원고는 장차 환율이 하락할 것이라는 예상을 한 나머지 그에 따른 환차익을 취득하려는 목적으로 장차 취득할 현물환 유입액을 훨씬 초과하여 단기간에 고 위험 구조의 이 사건 각 통화옵션계약 등 총 15건의 통화옵션계약을 체결하였고, 이로써 볼 때 원고는 장차 유입될 외환현물의 규모를 염두에 두고 환위험을 회피하기 위한 환 헤지 목적으로 계약을 체결한 것이 아니라 현물환 취득액과 상관없이 통화옵션계약을 통하여 환율 변동에 따른 환차익을 획득하려는 환투자 내지 환투기의 목적에서 이 사건 각 통화옵션계약을 체결하였다고 볼 수 있다(대법원 2013.9.26. 선고 2013나26746 전원합의체 판결).

(3) 델타헤지의 비율과 방식 - 서울고법 2010나71761 및 대법원 2013다3811 (ELS)

서울고등법원 2012. 12. 14. 선고 2010나71761 판결은 ELS 델타헤지의 적정성에 관한 판단기준을 제시하였다. 이 사건에서 대우증권은 2005년 11월 기초자산을 삼성SDI로 하는 ELS를 발행·판매하고, 발행에 따른 위험을 회피하기 위하여 삼성SDI 주식을 보유하며 델타헤지를 수행하였다. 2005년 11월 16일 조기상환 평가일 당일 14시 50분부터 15시까지 약 10분 동안, 대우증권은 삼성SDI 전체 거래량의 약 60%에 해당하는 물량을 집중 매도하였고, 이로 인해 종가가 하락하여 ELS 조기상환 조건이 불성취되었다. 원심은 델타헤지의 정당성을 인정하면서, 델타값과 실제보유수량이 완벽하게 일치하지 않고 넷델타 비율이 +15% 수준의 오버헤지 상태를 보이더라도, 델타값의 증감에 따라 실제보유수량을 증감시켜온 이상 넷델타값이 크다는 이유만으로 피고가 수행하여 온 헤지거래가 델타헤지에 부합하지 않는다고 단정하기 어렵다⁴¹⁾고 판시하였다. 그러나 대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다3811 판결은 이를 파기환송하면서, 단순한 헤지비율보다 위험회피거래가 시장가격 형성에 미치는 영향의 중립성과 행위의 공정성을 중심으로 판단하였다.

대법원은 “증권회사가 약정 평가기준일의 기초자산 가격 또는 지수에 연계하여 투자 수익이 결정되는 유가증권을 발행하여 투자자에게 판매함으로써, 발생한 기초자산의 가격변동에 따른 위험을 회피하고 자산운용의 건전성을 확보하기 위하여 위험회피거래를 하더라도 그 기초자산과 관련된 증권회사의 위험회피거래는 그 시기, 방법 등에 비추어 합리성이 인정되어야 하고, 그 과정에서 기초자산의 공정한 가격형성에 영향을 주어 투자자의 이익과 신뢰를 부당하게 훼손하여서는 아니 된다”고 판시하였다. 특히 대법원은 다음 요소들을 종합적으로 고려하여 위법성을 판단하였다. ①전체 거래량 대비 높은 시장점유율, ②종가 결정 직전 시간대(14:50~15:00)에의 집중 매도, ③조기상환 조건 성

41) 대체로 델타값보다 더 많게 실제보유수량을 유지하여 왔던 것으로 보인다(이른바 '오버헤지' 상태를 유지하여 왔다. 그로 인하여 2005. 7. 중순부터 이 사건 중간평가일인 2005. 11.16. 경까지의 넷델타 비율이 대체로 +15% 이상을 차지하고 있다). 다만 아래 그래프에서 알 수 있듯이 피고는 델타값의 증감에 따라 실제보유수량을 증감시켜온 사실은 인정할 수 있다(증감 수량이 정확히 일치하는 것은 아니나, 그 방향성은 대체로 일치하고 있다). 위와 같은 피고의 델타헤지 모습은 앞서 본 델타헤지의 기본원리에 정확하게 부합한다고 평가하기는 어려워 보인다. 다만 그렇다고 하더라도 트레이더에게는 일정한 위험수준 한도 내에서는 재량이 인정되는 것이므로 일관되게 오버헤지 또는 언더헤지 상태가 유지되고 있고, 그 델타값의 증감에 따라 실제보유수량을 증감시켜온 이상 넷델타값이 크다(혹은 넷델타 비율이 높다)는 이유만으로 피고가 수행하여 온 헤지거래가 델타헤지에 부합하지 않는다고 단정하기는 어렵다(서울고등법원 2012.12. 14. 선고 2010나71761 판결).

취 여부에 따라 필요 헤지물량이 크게 달라지는 이해상충 구조 (108,500원 이상 시 160,000주 필요, 108,000원 이하 시 95,000주 필요), ④이러한 상황에서 증가 형성에 직접적 영향을 미친 거래 방식. 대법원은 이를 종합하여 “피고의 이러한 행위는 원고들에 대한 투자자보호의무를 소홀히 한 것으로 신의성실에 반”한다고 판단하였다.

위 판결은 먼저, 델타헤지의 목적 자체는 정당하더라도 투자자 이익을 침해하는 방식으로 이루어지는 경우 위법이 될 수 있음을 확인하였다. 또한, 헤지비용의 정확성보다 거래시점·시장점유율 등 거래 방식의 적정성을 중요한 요소로 보았다. 마지막으로, 서울고법이 인정한 넷델타 +15%(즉, 115%) 범위는 ELS의 비선형 구조에서 델타값 변동성이 커 완전한 헤지가 구조적으로 어렵다는 점을 고려한 것이라고 판단된다. ETF는 기초지수와 선형 관계로 인해 델타값이 안정적으로 유지되므로, 동일한 기준(넷델타 115%)을 적용하더라도 ETF 특성상 과도하거나 불합리한 규제로 작용하지 않을 것이다. 다만 실무상 완벽한 헤지의 불가능성을 감안할 때 완벽한 100% 헤지를 요구하는 것은 비현실적이다. 따라서 비선형 ELS에서조차 재판상 쟁점이 된 115% 수준은, 델타값이 안정적인 선형 ETF의 경우 당연히 준수되어야 할 합리적 상한선으로 기능할 수 있으며, 이는 LP의 헤지거래가 시장 중립적 범위 내에서 이루어지고 있는지를 판단하는 기준점이 될 수 있을 것이다.

이상의 판례들은 ETF LP 헤지거래의 정당성 판단에 있어 대상성·목적성·비례성이라는 기준틀을 제공한다. 다만 이는 개별 금융상품의 구조와 맥락에서 형성된 법리로서, 선형 구조와 시장조성 기능이 결합된 ETF LP 거래에 대해서는 그 특수성을 반영한 별도의 해석기준이 필요함을 시사한다.

4. 감독 및 실효성 확보의 한계

(1) 헤지계좌 등록 제도의 불완전한 운영

(가) 규정 명문과 실무 운영의 괴리

한국거래소 유가증권시장 업무규정 및 시행세칙은, LP가 유동성공급계좌 개설 시 “유동성공급호가 제출과 관련된 헤지거래를 위한 계좌를 포함”하여 사전 신고하도록 규정하고 있다(2021. 8. 2. 시행)⁴²⁾. 그럼에도 실무상 LP는 선물 헤지계좌를 신고 대상에

포함하지 않고 있다. 이는 해당 규정이 유가증권시장 업무규정에 위치하고 있어 ‘주식 헤지계좌’만을 의미한다고 해석하는 관행에 기인한 것으로 보인다. 그러나 규정 문언은 “헤지거래를 위한 계좌”라는 포괄적 표현을 사용하고 있으므로, 선물계좌를 당연히 제외할 명확한 근거는 없어 보인다. 문제는 국내 지수형 ETF의 LP가 기초자산 현물보다 지수선물을 중심으로 헤지거래를 수행하는 것이 일반적인 점이다. LP가 선물헤지를 선호하는 이유는 ① 대차수수료가 발생하지 않고, ② 거래세가 면제되며, ③ 레버리지 활용이 가능하기 때문이다⁴³⁾. 지수형 ETF의 헤지거래가 대부분 선물을 통해 이루어지고 있음에도 이를 신고대상에서 제외하는 현행 실무는 규정의 본래 도입취지를 훼손할 우려가 있다. 더욱이 거래소 규정은 해당 계좌를 유동성공급 및 헤지 목적으로만 사용하도록 제한하는 명문 규정을 두고 있지 않아⁴⁴⁾, 실질적인 감독의 실효성을 확보하기 어렵다.

(나) 오버헤지 은폐의 구조적 가능성

선물 헤지계좌 미등록으로 인한 문제는 다음 사례를 통해 구체적으로 확인할 수 있다. LP가 KODEX200 ETF 100만주를 매수한 경우를 가정해보자. ①거래소에서 확인 가능한 내역: 기초자산 차입공매도 -50만주(헤지거래계좌 신고됨) ②거래소의 판단: 헤지비율 50%로, 과소헤지로 추정됨 ③실제 상황: 차입공매도 -50만주, KOSPI200 선물 매도 -70만주(헤지거래계좌 미신고 상태) → 총 120% 오버헤지

이러한 구조에서 거래소는 LP가 신고한 ETF 유동성공급계좌와 주식 헤지거래계좌의 내역만을 모니터링할 수 있을 뿐, 선물시장에서 이루어지는 헤지거래의 규모나 목적을 파악하기 어렵다. 더욱이 장외파생상품을 활용한 헤지거래에 대해서는 명문상 보고의무가 부재하여, 감독당국이 관련 정보를 실시간으로 확인하기 곤란하다. 따라서 LP의 실질적 헤지비율은 현행 감독체계만으로는 사전에 정확히 파악하기 어렵고, 이에 따라 현행 헤지계좌 등록 제도는 제도 도입의 본래 취지와 달리 감독기관이 ETF LP의 실질적 위

42) 거래소 업무규정 제20조의5 제2항 (2021. 3. 8. 신설); 같은 규정 시행세칙 제31조의6 제9항; 부칙 제1974호 (2021. 7. 20., 2021. 8. 2. 시행).

43) 선물은 대차수수료가 없고, 증권거래세가 면제되며(주식 0.15% vs 선물 0%), 적은 증거금(10-15%)으로 큰 포지션 구축이 가능하다. (2026년부터 증권거래세율이 0.05%포인트 인상됨)

44) 현행 규정은 계좌 신고 의무만 규정하고 사용 목적 제한은 명시하지 않는다. 실무상 한국거래소의 계좌 신고 시스템(EXture 3.0)에는 "유동성공급호가(헤지거래호가) 제출 용도로만 사용"이라는 안내 문구만 표시되나, LP가 헤지계좌를 다른 목적으로 사용하더라도 이를 제재할 명확한 근거가 없으며, 실질적으로는 각 증권사의 자율적 내부통제에 의존하는 구조이다.

협노출 및 오버헤지 여부를 효과적으로 검증하기 어려운 한계를 가지고 있다.

(2) 서브 LP 형태의 운영

LP는 다수의 ETF 운용사와 유동성공급 계약을 체결하더라도, 실제 유동성 공급은 거래량이 풍부하거나 관리가 용이한 대형 ETF 종목에 집중하는 경향을 보인다⁴⁵⁾. 이러한 구조하에서 하나의 ETF에는 실질적으로 유동성을 공급하는 주요 LP가 존재하고, 나머지는 형식적 계약관계에 머무는 이른바 ‘서브 LP’로 고착되는 현상이 발생한다. 그로 인해 시가총액이 작고 거래가 부진한 ETF의 경우, 적극적으로 호가를 제시하는 LP가 부재하여 유동성이 저하되고, 이는 괴리율 기준 초과와 주요 요인으로 작용한다⁴⁶⁾. 거래소 업무규정은 LP에게 괴리율 3%(해외 기초자산 ETF의 경우 6%) 이내 유지 의무를 부과하고 있으며⁴⁷⁾, 괴리율 초과는 해당 ETF의 모든 LP 평가에 부정적으로 반영된다. 한국거래소는 분기별 평가를 통해 LP에게 등급을 부여하고, ETF의 경우 ①매 분기 호가제출 의무 1시간 이상 위반 또는 괴리율 위반 매매일이 20일 이상이고, ②분기 평가에서 최하 등급을 받은 유동성공급회원이 있는 경우 운용사에게 해당 LP의 교체를 요구할 수 있다⁴⁸⁾.

그러나 실제로는 최근 5년간(2020~2024년 3분기) 총 14,051건의 괴리율 초과가 발생했음에도 D등급 이하 평가 사례는 단 6건(0.04%)에 불과한 것으로 나타났다. 이에

45) 2025년 10월 중 ETF 종목별 LP 거래현황은 다음과 같다(거래소 데이터 및 운용사 홈페이지 참조).

구분	일평균 거래대금	LP 계약 기관	월간 유동성 공급 기관	거래비율
KODEX 200	8,496억원	26개	21개	81% (21/26)
TIGER 200	2,009억원	28개	15개	54% (15/28)
TIGERFn 메타버스	5.9억원	19개	8개	42% (8/19)
KODEX메타버스 액티브	5.6억원	15개	5개	33% (5/15)

46) 한국경제 (2025.4.1.), "급증하는 ETF 괴리율 초과 공시" 2020년 한국거래소가 22개 주식 시장조성자의 3년 6개월 거래내역을 특별감리한 결과, 유동성이 풍부한 대형주에 편중되고 중소형주 유동성 공급은 소홀히 한 사실이 확인되었다; 금융위원회 보도자료(2020.12.18.), 시장조성자제도 개선 및 불법공매도 적발 강화를 통해 자본시장의 신뢰를 제고하겠습니다, 3-4면.

47) 거래소 업무규정 제20조의4 제1항 제2호. 국내기초자산의 경우 괴리율 3%, 해외기초자산의 경우 6% 이내 유지 의무. 다만 LP가 괴리율을 좁히지 못하는 데에는 구조적 제약도 존재한다. 펀드 대차한도 도달, 대차시장 유동성 부족, PBS 고금리 차입비용상승, 운용사의 환매제한, 시장 급변동 시 비용 급증 등으로 인해 유동성공급 및 헤지거래가 어려운 경우도 있다.

48) 같은 규정 제20조의6 및 시행세칙 제31조의10 두 가지 요건이 동시에 충족되어야 하므로, 괴리율 초과가 빈번하더라도 다른 평가항목(호가 스프레드, 제출수량 등)에서 양호하면 최하 등급을 받지 않아 교체 대상이 되지 않는다.

제재 제도가 실질적으로 기능하지 못하고 있다는 비판을 받는다⁴⁹⁾.

(3) 통합헤지 및 자동화 시스템의 감독 사각지대

2010년대 중반 이후 대형 LP사를 중심으로 이른바 ‘통합헤지’ 방식이 도입되었다. 이는 개별 ETF별로 독립적인 헤지를 수행하는 대신, 포트폴리오 전체의 순위험(Net Risk)을 기준으로 헤지 규모를 산정하는 방식이다. 예를 들어, LP가 KODEX200 ETF 100억 원 매수, TIGER200 ETF 80억 원 매도 포지션을 보유한 경우, 개별 ETF 단위로는 총 180억 원의 헤지가 필요하지만, 통합헤지 방식에서는 순포지션 20억 원에 대해서만 헤지를 수행한다. 문제는 현행 법령상 ‘정당한 헤지거래’의 명확한 기준이 부재한 상황에서, 각 LP가 자율적으로 통합헤지 로직을 설계·운영하고 있다는 점이다. 즉, ①어떤 ETF들을 하나의 포트폴리오로 묶을 것인지, ②전체 포트폴리오 기준으로 어느 수준까지가 ‘정당한 헤지’에 해당하는지에 대한 기준 자체가 존재하지 않는다. 더 나아가, 대형 LP 들은 자동화된 헤지 시스템을 활용하여 ㉠실시간 포지션 집계, ㉡헤지 필요량 산출, ㉢선물·현물 주문의 자동 실행, ㉣베이스스 변동 반영 조정 등의 절차를 전산화하고 있다⁵⁰⁾. 그러나 주문 실행 로직, 헤지 타이밍, 선물·현물 전환 기준 등 핵심 파라미터에 관한 가이드라인이나 감독 기준이 부재하며, 각 LP는 이를 독자적인 알고리즘에 따라 운영하고 있다. 이러한 구조하에서는 감독당국이 LP의 통합헤지 운용 실태를 적정 수준으로 모니터링하기 어렵다. 통합헤지 방식하에서는 개별 ETF 기준으로는 300% 수준의 오버헤지로 보이더라도, LP는 포트폴리오 전체의 순위험을 기준으로 정당한 헤지에 해당한다고 주장할 여지가 있다. 그 결과 현행 제도는 LP의 자율적 헤지 운용에 비해 감독의 실효성이 충분히 확보되지 못하고 있다.

49) 파이낸셜뉴스 (2024.12.24.), ETF 유동성공급자 평가 '구멍'... 1300억 손실 증권사 B등급 유지, 최근 5년간(2020년~2024년 3·4분기) 총 1만4,051건의 피리울 초과가 발생했으나, 분기별 LP 평가에서 D등급 이하 사례는 단 6건에 그쳤다.

50) 실무상 LP의 자동헤지 프로그램은 통상 ① 회사별 실시간 NAV 산출에 기초한 양방향 호가 제출, (예: NAV 대비 $\pm 20bp$) ② ETF 체결 시 위험 포지션의 개별 주식 분해 및 헤지 가능 자산 모니터링, ③ 노출 포지션이 사전 설정 임계치 초과 시 선물·주식바스켓·ETF 등 최적 헤지수단으로 자동 주문 생성 순서로 운용되는 것으로 알려져 있다. 동일 기초자산을 추종하는 복수 ETF 또는 상이한 기초자산 ETF 간의 헤지 물량 배분은 통합헤지 로직에 의해 결정되며, 블록딜·시장 상황에 따라 트레이더가 수기로 주문을 제출하기도 한다. 구체적인 운용 방식과 설정 기준은 LP별로 상이할 수 있다.

5. 소결

국내 법제는 ETF LP의 헤지거래와 관련하여 세 가지 구조적 한계를 드러낸다.

첫째, 실체적 기준의 부재이다. 자본시장법은 정당한 ‘헤지거래’를 명확히 정의하지 않으며, 시행령 제208조의2 역시 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”라는 추상적 표현에 그친다. 이로 인해 헤지와 투기의 경계가 모호해지고, LP는 대부분의 공매도를 ‘헤지 목적’으로 주장할 수 있는 여지를 가진다. 이러한 불명확성은 법적 예측가능성을 저해하고, 감독당국의 집행기준 또한 불안정하게 만든다. 둘째, 판례 법리의 적용 한계이다. 환헤지와 KIKO 사건 등에서 법원은 정당한 헤지거래의 요건으로 대상성·목적성·비례성을 제시하였으나, KIKO 및 ELS는 비선형 구조의 상품이다. 반면 ETF LP 거래는 선형적 구조이면서 동시에 시장조성 기능이 결합된 복합적 형태를 가지므로, 기존 판례의 직접 준용은 한계가 있다. 따라서 ETF LP 헤지거래의 특수성을 반영한 별도의 해석기준이 마련될 필요가 있다. 마지막으로, 감독 인프라의 미흡이다. 선물 헤지계좌와 신고의무와 통합·자동헤지 프로그램에 대한 가이드라인이 마련되어 있지 않아, 감독당국은 LP의 실질적 헤지 운용을 실시간으로 파악하기 어렵다. 이로 인해 LP의 자율성에 비해 감독의 실효성이 미흡한 체계가 형성되어 있으며, 통합·자동헤지 운용의 투명성 확보에도 제도적 제약이 존재한다. 이러한 한계는 정당한 헤지거래의 명확한 판단기준의 정립을 통해서만 극복될 수 있다. 다음 장에서는 주요국의 규제체계를 비교법적으로 분석하고, 이를 토대로 국내 법제의 개선 방향과 구체적 판단기준을 제시하고자 한다.

IV. 주요국의 헤지거래 규율체계

1. 미국의 규율체계⁵¹⁾

(1) SEC의 ETF 규제와 AP의 역할

미국 증권거래위원회(SEC)는 2019년 「Rule 6c-11」을 제정함으로써 ETF에 대한 포괄적 규제 체계를 확립하였다. 「Rule 6c-11(a)(1)」은 Authorized Participant(AP)를 “SEC에 등록된 청산기관의 회원 또는 참가자로서, ETF 또는 그 서비스 제공자와 서면 계약을 체결하여 설정단위(creation unit)의 매입 및 환매 주문을 할 수 있는 자”로 정의한다⁵²⁾. 이는 한국의 지정참가회사 제도와 유사한 구조다.

(2) 정당한 시장조성(bona fide market making)의 핵심 기준

미국의 규제체계는 ‘bona fide market making’ 개념을 중심으로 구성된다.

(가) 양방향 호가 제시 의무

FINRA Regulatory Notice 06-53은 정당한 시장조성의 핵심 기준을 제시하고 있다. 해당 고시에 따르면, 시장조성자가 지속적으로 최고 매도호가 부근에만 위치하고 최고 매수호가 부근에는 위치하지 않는 경우, 일반적으로 정당한 시장조성으로 인정되지 않는다. 즉, 시장조성자는 매수호가와 매도호가 양측에서 정기적이고 지속적으로 호가를 제시해야 하며, 공매도를 실행하는 시점에 해당 종목에서 실제로 시장조성 활동을 수행하고 있는 경우에 한해 예외적 지위를 인정받을 수 있다⁵³⁾. 나아가 FINRA는 감독보고

51) Volcker Rule은 Dodd-Frank Act § 619에 근거하여 연방은행감독기관이 제정한 시행규칙(예: 12 C.F.R. Part 248)이며, FINRA는 SEC 감독 하의 자율규제기구로서 그 규칙(FINRA Rules)은 회원사에 대해 구속력을 가지며, Regulatory Notice는 규칙의 해석·적용 기준을 제시하는 공식 guidance로 활용된다.

52) 17 C.F.R. § 270.6c-11(a)(1) (2019). Securities and Exchange Commission, Exchange-Traded Funds, 84 Fed. Reg. 57,162 (Oct. 24, 2019) (codified at 17 C.F.R. § 270.6c-11), <https://www.federalregister.gov/d/2019-21250>

53) Financial Industry Regulatory Authority, Notice to Members 06-53, Guidance on the

서에서 “거래소의 시장조성자 지정과 호가 요건 준수에 의존하고 이를 준수하는 것만으로는 정당한 시장조성자 예외 자격이 자동으로 부여되지 않는다”고 말한다.⁵⁴⁾ 이는 형식적 요건이 아닌 실질적 거래 행태를 기준으로 예외 적용 여부를 판단한다는 점을 명확히 한 것으로 이해된다. 다시 말해, 시장조성자 지정만으로는 공매도 예외가 인정되지 않으며, 해당 거래가 실제로 시장의 유동성 공급이라는 기능적 목적을 수행하고 있는지 여부가 핵심 판단기준이 된다.

(나) 정당한 시장조성의 범위와 한계

FINRA는 시장조성이 브로커-딜러의 투기적 판매전략이나 자체 투자결정과 관련된 활동을 포함하지 않는다고 명시한다⁵⁵⁾. 이는 시장조성의 목적이 단기적 수익창출이 아니라 유동성 공급과 가격발견 기능의 유지에 있음을 전제로 한다. 또한, 시장조성자가 자신의 제시 호가를 벗어나 지속적으로 공매도를 실행하는 경우에도 정당한 시장조성 예외에 해당하지 않는다고 본다⁵⁶⁾. 결국 FINRA는 시장조성자 지정이라는 형식이 아니라, 해당 거래가 유동성 공급이라는 공적 기능에 실제로 기여하고 있는지를 기준으로 bona fide 여부를 판단하는 것이다.

(다) 규제 편익: 공매도 규제 예외

Regulation SHO Rule 203(b)(2)는 시장조성자가 정당한 시장조성 활동과 관련하여 실행하는 공매도(short sale)에 대하여 locate 요건(차입 또는 차입 가능성의 사전 확인 의무)을 면제하고 있다⁵⁷⁾. 다만 FINRA와 SEC는 이러한 예외를 형식적 지위에 근거하

Requirements for Availability of Bona Fide Market Making Activity Exception to NASD Rule 5100, at 2 (Sept. 2006).

54) FINRA, 2023 Report on FINRA's Examination and Risk Monitoring Program, Regulation SHO - Bona Fide Market Making Exemptions, at 61.

55) FINRA Regulatory Notice 06-53 (Sept. 2006); Securities Exchange Act Release No. 50103 (July 28, 2004), 69 FR 48008, 48015 (August 6, 2004) (Regulation SHO Adopting Release).

56) Securities Exchange Act Release No. 50103, 69 FR 48008, 48015 (Aug. 6, 2004); FINRA Regulatory Notice 06-53, at 2 (Sept. 2006).

57) 17 C.F.R. § 242.203(b)(2)(iii) (Regulation SHO의 locate 요건 예외 - 정당한 시장조성 활동과 관련된 시장조성자의 공매도).

여 자동적으로 부여하지 않는다. 양 기관은 거래의 실질을 기준으로 시장조성 여부를 심사한다⁵⁸⁾⁵⁹⁾.

(3) Volcker Rule: 정당한 헤지거래의 요건과 과도한 헤지 금지

2010년 제정된 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 619는 Volcker Rule로 알려진 Bank Holding Company Act § 13(12 U.S.C. § 1851)을 신설하여, banking entities(은행, 은행지주회사 및 그 계열사 등)의 투기적 자기매매를 원칙적으로 금지하였다. 단, 정당한 헤지거래(bona fide hedging) 및 시장조성(market-making) 활동은 예외로 인정된다⁶⁰⁾. 이후 연방은행감독기관들이 공동 제정한 시행규칙(12 C.F.R. Part 248 등)은 허용되는 위험완화 헤지활동의 요건을 구체적으로 규정하는 한편, 과도한 헤지를 명시적으로 제한하고 있다.

(가) Volcker Rule이 제시하는 정당한 헤지거래의 요건⁶¹⁾

① 헤지 대상 포지션의 명확한 식별이다(§248.5(b)(1)(ii)(B)).

헤지 활동은 은행 엔티티의 개별적 또는 집합적 포지션·계약·보유자산과 직접 관련되어야 하며, 그 포지션에 수반되는 특정하고 식별 가능한 위험을 감소시키도록 설계되어

58) 미국은 공매도 시 원칙적으로 누구에게도 업틱롤이 강제되지 않아 따로 시장조성자를 예외 처리할 필요가 없다. 단 주가가 전일 대비 10%이상 하락한 종목에 대해서 익일까지 업틱롤 적용 17 C.F.R. § 242.201.(b)(1)·(b)(3), 차익거래 등 예외 다만, SEC는 Rule 201(d)(3)의 domestic arbitrage exception이 ETF 주식과 기초자산 간의 차익거래에는 적용되지 않는다는 점을 명확히 하였다. SEC, Division of Trading and Markets, Responses to Frequently Asked Questions Concerning Rule 201 of Regulation SHO, Question6.5&Answer, <https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/trading-markets-frequently-asked-questions-7>

59) 또한, 공매도 금지 시 시장조성자 등의 예외를 인정하는 것은 국제적으로 일반적인 관행이다. 2008년 금융위기 당시에는 미국, 영국, 일본 등 9개국이, 2011년 유럽 재정위기 때에는 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 6개국이, 2020년 3월 코로나19 위기 시에는 유럽 6개국(그리스, 오스트리아, 이탈리아, 벨기에, 프랑스, 스페인)이 시장조성자 등에게 공매도 예외를 인정하였다(한국거래소 외, 2021, 공매도 사실은 이렇습니다).

60) Dodd-Frank Act § 619 (codified at 12 U.S.C. § 1851; hedging exception at § 1851(d)(1)(C)) <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/12/1851>

61) 12 CFR § 248.5 - Permitted risk-mitigating hedging activities, available at: Cornell Law : <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/248.5> Federal Register 79 FR 5536, 5621 (Jan. 31, 2014): <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-01-31/pdf/2013-31511.pdf> 본 논문에서는 12 CFR § 248.5의 여러 조항들을 헤지거래의 관점에서 정리하여 제시함

야 한다.

② 헤지 비율의 적정성 및 비례성 - 실증적 효과이다(§248.5(b)(1)(ii)(B), (b)(1)(i)(C)). 헤지 활동은 식별된 위험의 규모 및 특성에 비례하여 합리적으로 설계되어야 하며,

그 효과는 분석과 독립적 검증을 통해 실제로 위험을 감소·완화함이 입증되어야 한다. 이는 헤지 비율의 적정성과 비례성 및 실증성을 요구한다.

③ 헤지 전략의 문서화 의무이다(§248.5(c)(2)). 헤지 개시 시점에 거래가 감소시키려는 위험의 구체적 내용, 이를 이행하기 위한 위험완화 전략, 그리고 해당 거래를 수행·관리하는 트레이딩 데스크 또는 사업 단위를 명확히 문서화(documentation)해야 한다.

④ 새로운 위험의 비발생 요건이다.(§ 248.5(b)(1)(ii)(C)). 헤지 활동은 개시 시점에 새롭게나 추가적인 비헤지 위험을 발생시켜서는 안 되며, 불가피하게 생기는 경우에는 동시에 헤지 되어야 한다.

⑤ 지속적 검토 및 재조정 요건이다(§248.5(b)(1)(ii)(D)). 헤지 효과성을 보장하기 위해 해당 거래는 지속적으로 검토·모니터링·관리되어야 하며, 시장 상황의 변화에 따라 적정 수준으로 재조정되어야 한다.

⑥ 독립적 검증 및 내부통제 시스템 구축 의무이다(§248.5(b)(1)(i)). 은행 엔티티(banking entities)는 허용되는 포지션, 기법 및 전략에 관한 서면 정책과 절차를 마련하고, 헤지 효과를 검증하기 위한 분석·테스트·상관분석 등의 독립적 검증체계 및 지속적 모니터링·승인 절차를 포함한 내부통제 프로그램을 운영해야 한다.

⑦ 보상체계의 중립성 요건이다(§248.5(b)(1)(iii)). 헤지 활동을 수행하는 직원의 보상체계는 금지된 자기매매를 보상하거나 장려하도록 설계되어서는 안 되며, 보상은 위험관리 성과에 기초해야 한다.

(나) 포트폴리오 헤지의 허용

Volcker Rule은 “개별적 또는 집합적 포지션(individual or aggregated positions)”의 헤지를 허용함으로써⁶²⁾, 각 포지션마다 완전한 1:1 대응 헤지를 요구하지 않는다. 이는 개별 포지션의 위험을 개별적으로 상쇄하기보다는, 포트폴리오 전체의 체계적 위험

(systematic risk)을 통합적으로 관리하는 접근을 인정한 것이다. 다만, 포트폴리오 단위로 헤지를 수행하는 경우에도 비례성 원칙은 여전히 적용된다. 즉, 헤지 규모가 대상 위험의 규모를 합리적 범위를 넘어 초과해서는 안 된다.

2. 캐나다의 규율체계 (ETF 최초 상장)

(1) CIRO의 설립과 ETF 시장 구조

캐나다의 투자산업 자율규제기관인 Canadian Investment Regulatory Organization(CIRO)는 ETF 시장조성자를 포함한 투자 딜러의 거래 행위를 규율한다. 캐나다 ETF 시장에서는 Designated Broker(DB)가 미국의 Authorized Participant(AP)와 유사하게 ETF 유닛의 설정·환매 및 시장조성 기능을 수행한다. DB는 ETF 발행사와 designated broker agreement를 체결하여 양방향 호가를 제시하며, 이 과정에서 발생하는 일중 위험을 헤지할 필요가 있다⁶³⁾.

(2) CIRO의 헤지거래 정의와 인정 원칙

(가) UMIR의 헤지 거래 정의

CIRO의 「Universal Market Integrity Rules(UMIR)」⁶⁴⁾ 제1.1조(Section 1.1)는 ‘헤지(hedge)’를 다음과 같이 정의한다. “해당 증권 또는 관련 증권의 이전 매수 또는 매도에서 부담한 위험, 또는 이후 매수 또는 매도에서 부담할 위험을 전부 또는 부분적으로 상쇄(offset)하기 위한 증권의 매수 또는 매도.”⁶⁵⁾ 이는 헤지의 본질을 ‘위험의 상쇄

62) 12 CFR § 248.5(a).

63) Canadian Securities Administrators, Decision of OSC Re: Vanguard Investments Canada Inc. (2024). 캐나다 ETF 시장에서 Designated Broker(DB)는 ETF 발행사와 designated broker agreement를 체결하여 Creation Unit(CU) 설정 및 환매를 수행한다. 이와 구별하여 일반 딜러(Dealer)는 continuous distribution dealer agreement를 체결한다. <https://www.osc.ca/en/securities-law/orders-rulings-decisions/vanguard-investments-canada-inc-6>

64) CIRO, "Universal Market Integrity Rules," <https://www.ciro.ca/rules-and-enforcement/universal-market-integrity-rules>. UMIR은 CIRO가 제정하고 관할 증권위원회의 승인을 받은 자율규제 규칙으로서, 위반 시 제재가 가능한 구속력 있는 규범이다. 캐나다는 주·준주별 증권법 체계를 취하며, CSA의 National Instruments를 통해 전국 통일 규정을 마련하고, CIRO 등 SRO가 자율규제를 담당한다.

(risk offset)‘로 명확히 규정한 것으로, 국내 법제가 ‘경제적 손실을 줄이기 위한 거래‘라는 포괄적 개념에 그치고 있는 것과 달리, 법규 차원에서 헤지의 정의를 구체적으로 명문화하고 있다는 점에서 주목할 만하다.

(나) IDPC Rules의 헤지 주체(Hedger) 인정 기준

CIRO는 IDPC Rules 1201(2)의 "헤지 주체(hedger)" 정의를 적용·해석하는 Guidance Note에서, 투자 딜러(Investment Dealer)가 중개업(brokerage) 기능을 수행하면서 고객의 파생상품 거래를 취급할 때, 해당 고객을 "헤지 주체(hedger)"로 분류하기 위한 다음의 기준을 제시한다⁶⁶⁾.

① 위험 상쇄 원칙(No More Than Offset)이다. “거래는 헤지 대상자의 노출에 부수적인 가격 위험을 상쇄하는 것 이상이어서는 안 된다.” 이는 헤지거래가 위험의 제거 또는 완화라는 본래 목적을 초과하지 않아야 함을 제시한 해석 원칙으로, 과도한 헤지를 제한하는 원칙이다.

② 투기 거래의 배제이다. CIRO는 헤지 개념이 "투기자에게는 적용되지 않는다(It is not intended to apply to speculators)"고 명시함으로써, 헤지거래가 사업상 위험관리를 목적으로 해야 하며 시장 변동성으로부터의 이익 추구는 정당한 헤지의 범위를 벗어남을 분명히 한다.

(다) ETF 시장조성자 특례: Minimal Exposed Risk 기준

CIRO는 ETF 시장조성자에 대하여 별도의 예외 규정을 두고 있다. 2016년 개정된 Short-Marking Exempt Order Definition은 다음과 같이 규정한다.

65) CIRO, Universal Market Integrity Rules (UMIR), Section 1.1. "Hedge". <https://www.ciro.ca/rules-and-enforcement/universal-market-integrity-rules/11-definitions>.

66) CIRO, Investment Dealer and Partially Consolidated Rules (IDPC Rules), Rule 1201(2); CIRO, Guidance Note GN-1200-24-001, "Applying and interpreting the definitions of 'hedger' and 'institutional client'" (Sept. 28, 2024). IDPC Rules는 기관투자자(institutional client)와 소매 고객(retail client)을 구별하여 차등화된 규제를 적용한다. 헤지 주체(hedger)가 동의하여 기관투자자로 분류될 경우, 투자 딜러는 고객 파악 및 적합성 심사(IDPC Rule 3208(1)(iv), 3403) 등의 의무가 면제되거나 완화된다. <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/applying-and-interpreting-definitions-hedger-and-institutional-client>

“ETF 시장조성자는 해당 계정이 매 거래일 종료 시 최소한의 노출 위험(minimal exposed risk)만을 보유하는 한, 모든 주문에 Short-Marking Exempt(SME) 표시를 할 수 있다.”⁶⁷⁾ 이 규정의 핵심은 minimal exposed risk 개념에 있다. 이는 통상적인 방향성 중립(directionally neutral) 개념과 구별된다. 즉, directionally neutral은 거래 종료 시점에 포지션이 완전히 ‘0’이 되어야 함을 의미하지만, minimal exposed risk는 일정 수준의 잔여 포지션을 허용한다는 점에서 보다 현실적 개념이다. CIRO가 이러한 특례를 인정한 이유는, ETF와 기초자산 간의 완벽한 헤지가 실무적으로 불가능하다는 점을 제도적으로 반영한 것으로 보인다. ETF 시장조성자는 거래의 연속성과 유동성 공급을 위해 일시적 포지션 불일치를 감수할 수밖에 없으며, minimal exposed risk 기준은 이러한 현실적 제약을 고려하여 허용 가능한 범위 내에서의 불가피한 헤지 불완전성을 제도적으로 인정한 것으로 평가된다. CIRO의 최신 가이드라인은 ETF 시장조성자의 SME 자격 요건을 보다 구체화하여, ①해당 ETF에 대한 Marketplace Trading Obligations 보유 또는 면제 ETF의 지속적 분배 계약(continuous distribution agreement) 체결, ②주문이 해당 ETF 또는 기초자산의 기존 포지션을 헤지하기 위한 것일 것, ③통상적으로 매 거래일 종료 시 minimal exposed risk 이하를 유지할 것이라는 세 가지 요건을 충족하도록 규정하고 있다⁶⁸⁾.

67) IIROC Notice 16-0028, "Amendment to the Short-marking Exempt Order Definition" (Feb. 11, 2016); CIRO, Guidance Note GN-URPART6-25-0002, "Guidance on 'Short Sale' and 'Short-Marking Exempt' Order Designations" (Aug. 19, 2025). "ETF 시장조성자는 해당 계정이 매 거래일 종료 시 최소한의 노출 위험(minimal exposed risk)만을 보유하는 한 모든 주문에 Short-Marking Exempt(SME) 표시를 할 수 있다." Minimal exposed risk는 directionally neutral과 달리 소량의 잔여 포지션을 허용하며, CIRO는 ETF 시장조성 활동에서 일중 완벽한 헤지 유지의 운영상 어려움을 인정한 것으로 평가된다. <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/guidance-short-sale-and-short-marking-exempt-order-designations-0>

68) CIRO, Guidance Note GN-URPART6-25-0002, "Guidance on 'Short Sale' and 'Short-Marking Exempt' Order Designations" (Aug. 19, 2025), Section 1.2, paragraph (e). <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/guidance-short-sale-and-short-marking-exempt-order-designations-0>

3. 유럽연합(EU) 및 영국의 규율체계⁶⁹⁾

(1) 규제체계의 구조

유럽의 ETF 시장조성자 헤지거래 규율은 세 단계의 규범 체계로 구성된다. 먼저 MiFID II(Directive 2014/65/EU)가 시장조성(market making)의 정의와 시장조성자의 의무를 규정하는 기초법제로 기능한다. MiFID II 제4조 제1항 제7호 및 제17조 제4항은 시장조성 전략을 확정적이고 동시적인 양방향 호가를 경쟁적 가격에 제시하여 시장에 정기적이고 지속적으로 유동성을 공급하는 행위로 구체화하고 있으며, 제17조 제3항은 이를 수행하는 투자회사에 거래소와의 서면 합의 체결 의무를 부과하고 있다⁷⁰⁾. 이는 시장조성의 본질이 양방향 유동성의 지속적 공급에 있음을 확인한 것으로, 미국 FINRA의 bona fide market making 기준과 구조적으로 유사하다. 또한 Short Selling Regulation(SSR, (EU) No 236/2012)이 시장조성자에 대한 공매도 규제 예외의 근거를 제공하며, 마지막으로 시장남용규제(Market Abuse Regulation, MAR, (EU) No 596/2014)가 시장조성자의 정당한 행위에 관한 판단 기준을 제시한다.

(2) SSR에 의한 시장조성 예외와 비례성 원칙

SSR 제17조 제1항은 시장조성 활동으로 인해 수행되는 거래에 대하여 순공매도 포지션의 보고·공시 의무(제5조, 제6조, 제7조) 및 무차입 공매도 제한(제12조, 제13조, 제14조)의 적용을 면제한다⁷¹⁾. SSR 제2조 제1항 (k)호는 시장조성 활동을 정의하면서, 여기에 시장조성 과정에서 발생하는 포지션의 헤지(hedging)를 명시적으로 포함한다⁷²⁾. ESMA(European Securities and Markets Authority)는 동 규정의 해석·적용에

69) SSR 및 MAR은 회원국에 직접 적용되는 법규(Regulation)이며, MiFID II는 회원국이 국내 법으로 전환해야 하는 지침(Directive)이다. ESMA 가이드라인은 특히 SSR상 시장조성 예외의 해석·적용을 조화시키는 감독상 지침(guidance)으로 기능한다. 영국의 UK MAR은 브렉시트 이후 영국법으로 온쇼어링되어 assimilated law로서 운영되고 있으며, FCA Handbook MAR 1.3 등 관련 규정이 구체적 적용 지침을 제시한다.

70) Directive 2014/65/EU (MiFID II), art. 4(1)(7), art. 17(3) 및 art. 17(4). Art. 4(1)(7)은 시장조성자(market maker)의 주체 정의를, art. 17(4)는 시장조성 전략(market making strategy)의 행위 요건을, art. 17(3)은 이를 수행하는 투자회사의 서면 합의 체결 의무를 각각 규정한다. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0065>

71) Short Selling Regulation (EU) No 236/2012, art. 17(1). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0236>

관한 가이드라인을 통해, 헤지 포지션의 규모가 헤지 대상 익스포저에 비례 (proportionate to the size of the exposure hedged)해야 하며, 정확한 매칭이 불가능한 경우에도 불일치는 미미한 수준에 그쳐야 하고, 그 사유를 감독기관에 소명해야 한다고 규정한다⁷³⁾. 유럽 규제체계의 특징은 헤지거래의 구체적 방법을 열거하지 않고 합리성·투명성·위험의 균형이라는 원칙 중심 규율을 채택한 점이다.

(3) MAR에 의한 정당한 행위 기준

MAR 제9조는 시장남용 판단에서 '정당한 행위(legitimate behaviour)'의 범위를 규정한다. 특히 동조 제2항 (a)호는 시장조성자가 내부정보를 보유하고 있는 경우에도, 해당 거래가 시장조성 기능의 정상적인 수행과정(normal course of the exercise of its function as a market maker)에서 정당하게 이루어진 것이라면 내부자거래로 간주되지 않는다고 규정한다⁷⁴⁾. 이는 EU가 시장조성 활동을 정당한 행위로 인정하는 규제 태도를 보여주는 것으로, SSR의 공매도 예외와 함께 시장조성자의 법적 지위를 뒷받침하는 근거가 된다.

(4) 영국의 규율체계

영국은 브렉시트 이후 2020년 12월 31일 EU MAR을 UK MAR로 온쇼어링 하였으며, EU MAR의 기본 구조를 유지하면서도 The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/310)를 통해 영국 독자적 규제체계로 작동하도록 수정하였다⁷⁵⁾. 영국 FCA Handbook MAR 1.3은 시장남용 판단 시 “해당 인물의 행위가 부담한 위험에 비례하는지(proportional to the risk undertaken)”를 명시적 고려 요소로 규정하

72) SSR, art. 2(1)(k). 시장조성 활동에는 (i) 양방향 호가의 지속적 제시, (ii) 고객 주문의 이행, (iii) 전 두 호에 해당하는 활동으로 인해 발생하는 포지션의 헤지가 포함된다(위 주 70) 링크 참조).

73) ESMA, Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) No 236/2012 (ESMA/2013/74, 2 April 2013), para. 25. <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-74.pdf>

74) Regulation (EU) No 596/2014 (MAR), art. 9(2)(a). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596>

75) The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/310). [영국의 법정 명령(Statutory Instrument)으로서, EU법을 영국법으로 전환하는 2차 입법] <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/310/contents/made>

며⁷⁶⁾, 헤지거래가 “정당한 사업으로부터 발생하는 위험을 중화(neutralise)하고 대응하는 정도”를 판단 기준으로 제시한다⁷⁷⁾. 이는 EU의 SSR 및 ESMA Guidelines에서 제시된 비례성 원칙을 FCA Handbook 차원에서 더욱 명확하게 규정한 것으로, 헤지거래의 정당성이 실제 사업상 위험과의 관련성 및 비례성에 달려 있음을 확인한 것이다.

[표 1] 주요국 헤지거래 규제 비교

구분	미국	캐나다	유럽
헤지 정의	특정하고 식별 가능한 위험을 감소시키는 거래 Volcker Rule §248.5	위험을 전부/부분적으로 상쇄하기 위한 거래 UMIR Section 1.1	실제 위험 노출과 비례하는 거래 SSR Art. 2(1)(k) / ESMA Guidelines para. 25
대상성	specific position - 특정 포지션의 객관적 확인	해당 증권의 위험 이전 / 이후 거래로부터 발생한 위험	actual risk exposure 실제 위험 노출
목적성	bona fide market making - 투기 목적 명시적 금지	투기 배제 원칙 "hedger 개념 투기자 배제"	정당한 행위(legitimate behaviour) 기준 MAR Art. 9(2)(a)
비례성	proportional to risk - 위험과 비례 Volcker Rule	no more than offset - 위험 상쇄 이상 금지 IDPC Rules GN	proportionality principle - 실제 위험과 비례 ESMA para. 25 / FCA MAR 1.3

4. 소결

주요국의 헤지거래 규제는 제도적 맥락과 적용 대상이 상이하나, 헤지거래의 본질적인 원칙은 공통적으로 확인된다. 미국 Volcker Rule의 "특정하고 식별 가능한 위험", 캐나다 UMIR의 "이전·이후 거래로부터 발생한 위험", EU의 MiFID II에 의한 시장조성자 정의 및 SSR·ESMA 가이드라인의 비례성 원칙은 모두 ①헤지 대상의 명확한 존재(대상성), ②투기가 아닌 위험회피 목적(목적성), ③실제 위험에 비례하는 규모(비례성)를 요구한다. 이러한 원칙은 주요국 규제의 공통된 축을 이루며, 완전한 헤지가 구조적으로 불가능하다는 인식 아래 합리적 범위의 부분·통합헤지를 허용한다. 형식보다 실질을 중

76) FCA Handbook MAR 1.3.15G(4) <https://api-handbook.fca.org.uk/files/sourcebook/MAR.pdf>

77) FCA Handbook MAR 1.3.10G(1)(위 홈페이지 참조).

시하는 점도 공통적이다. 주목할 점은 이러한 기준들이 법률, 규정, 자율규제 등 다양한 규범 형식을 통해 구현되고 있다는 사실이다. 반면 한국은 헤지거래에 대한 법규상 정의가 부재하며, LP에 적용되는 시행령 제208조의2는 보고의무 면제 요건만을 극히 포괄적으로 규정하여 비례성 기준이 없다. 이로 인해 대부분의 공매도가 '헤지 목적'으로 주장이 가능한 법적 공백이 존재한다.⁷⁸⁾ 따라서 주요국의 헤지거래 규제는 한국의 현행 규제체계를 평가하고 개선방향을 모색하는 데 중요한 참고점이 될 수 있을 것이다. 나아가 본 논문에서 검토한 미국·캐나다·EU 외에도 호주·홍콩·일본 등 주요국은 공통적으로 시장조성자에 대해 공매도 예외를 부여하되, 그 범위를 시장조성 활동 및 이에 수반되는 포지션의 헤지에 한정하고 있다. 특히 호주와 홍콩은 시장조성자의 헤지 목적 공매도를 기존 포지션의 헤지에 한정하고, 선행헤지(pre-hedging)에는 동 예외가 적용되지 않는다는 점을 명시하고 있다. 이러한 규율 태도는 IOSCO가 공매도 규제의 원칙으로서 시장 기능을 위한 적절한 예외의 허용을 권고한 취지와도 부합한다.⁷⁹⁾

V. LP 헤지거래의 유형별 분석 및 적법성 판단

1. 적법성 판단의 기본 원칙

III장과 IV장에서 확인한 바와 같이, 정당한 헤지거래는 대상성·목적성·비례성의 3대

78) 시행령 제186조의2는 '손익의 범위를 초과하지 아니할 것'을 명시하나, 이는 일반투자자 보호를 위한 장외파생상품 거래금지 예외(법 제166조)로 ETF LP에 직접 적용된다고 볼 수 없다.

79) IOSCO, Regulation of Short Selling – Final Report (IOSCOPD292, June 2009), Principle 4. 호주: ASIC Corporations (Short Selling) Instrument 2018/745 §5.6; ASIC RG 196.46~60 참조. 특히 RG 196.57은 "pre-emptive hedging"을 예상되었으나 현재 존재하지 않는 위험(anticipated but not current risk)의 헤지로 정의하고 이를 동 면제의 적용범위에서 명시적으로 배제한다. 다만 시장조성자가 상품의 발행·취득·처분에 관하여 이미 합의하였으나 조건이 아직 충족되지 않은 상태에서의 헤지는 선행헤지에 해당하지 않으며, 특히 상품의 가격이 헤지 가격에 의해 결정되는 경우에는 더욱 그러하다(RG 196.59). 홍콩: SFO (Cap.571) §170(3)(e); SEHK Rules Schedule 11; SFC Guidance Note on Short Selling Reporting, §2.5.3~2.5.4. 특히 §2.5.4(f)는 헤지 목적 공매도가 기존 포지션(existing positions)의 헤지를 위해서만 이루어져야 하며 선행헤지(pre-hedging)에는 적용되지 않는다고 규정한다. 일본: 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 Art.9-3(1)(v), Art.11, Art.15(1)(i).

기준으로 판단할 수 있다. 다만, 대상성과는 달리 목적성은 행위자의 내심의 의사로 직접 판단하기 어렵고 비례성 또한 구체적인 기준을 제시하는데 어려움이 있다. 그럼에도 본 논문은 3대 기준을 통해 정당한 헤지를 어떻게 해석해야 하는지 가이드를 제시하고자 한다.

(1) 대상성 판단기준

헤지 대상의 대상성은 다음과 같이 판단한다

ETF 포지션의 존재: LP가 실제로 ETF 매수 또는 매도 포지션을 보유하고 있는가?

포지션의 식별 가능성: 헤지 대상 포지션이 거래 시스템상 명확히 기록되어 있는가?

시간적 연관성: 헤지거래가 포지션 보유 시점과 합리적 시간 내에 이루어졌는가?

→ 대상성 결여 사례⁸⁰⁾: ETF 포지션 없이 선물 또는 현물(기초자산)만 거래: 헤지 대상이 존재하지 않으므로 순수한 투기거래에 해당할 수 있다(예외 아래 2절 참조).

(2) 비례성 판단기준

비례성 판단에서 핵심적인 쟁점은 ‘얼마나 정확한 헤지를 요구할 것인가’이다. 그러나 ETF LP 헤지거래에서 완벽한 100% 헤지를 달성하는 것은 실무적으로 불가능하다.

ETF 포지션과 헤지 수단 간에는 구조적 괴리가 존재하여 완전한 100% 헤지는 달성될 수 없다. ETF 매매 체결과 헤지 주문의 집행 사이에는 불가피한 시간차가 발생하며, 이 짧은 시차 동안에도 가격 변동이 일어나 의도한 헤지비율을 정확히 유지하기 어렵다. 또한 ETF 거래와 헤지 수단(선물·현물) 거래는 각각 상이한 수수료, 세금, 대차비용 등이 부과되어 이론적 헤지비율과 실제 달성 가능한 비율 간에 괴리가 발생한다. 특히 현물 헤지 시에는 증권거래세와 대차수요가 발생하는 반면, 선물 거래에는 거래세가 면제되므로 헤지 수단의 선택에 따라 실제 달성 가능한 헤지비율이 달라지고 완전한 헤지는 구조적으로 제약된다. 따라서 완벽한 헤지가 불가능하다는 현실을 고려할 때, 법적

80) 대상성의 판단 시점은 헤지거래 주문 시점의 순포지션을 기준으로 한다. 이는 공매도의 적법성 판단에서 주문 시점의 잔고를 기준으로 삼는 것과 같은 맥락이다.

판단은 ‘합리적 범위’ 내의 헤지를 인정해야 한다. 본 연구는 다음과 같은 기준을 제시한다.

$$\text{헤지비율(체결기준)} = (\text{전체 헤지 거래대금})^{81)} / (\text{전체 ETF 거래대금}) \times 100\%$$

이 기준에 따라 본 연구는 115%를 합리적 상한선으로 제안하며 그 근거는 다음과 같다. 먼저, ELS 델타헤지 판례(서울고법 2010나71761)가 제시한 115%⁸²⁾는 실무에서 운용되던 비선형 구조의 헤지거래 사안에서 법원에 의해 합리적인 범위로 인정받은 기준이다. ETF는 기초자산과의 선형성이 높아 이론적으로는 더 정밀한 헤지가 가능하다. 또한 KIKO 판례(대법원 2013다26746)는 헤지 대상의 1.7배(170%) 계약을 과도한 헤지로 판단하였으나, 그 이하 구간에 대한 명확한 기준을 제시하지 않았다. 115%는 100%(이론적 완전헤지)와 170%(명백한 과잉헤지) 사이에서, 실무적 제약을 고려한 합리적 버퍼를 인정하는 수준이다. 마지막으로, LP가 통합헤지(portfolio hedging) 방식을 사용하는 경우 양방향 포지션의 상계(netting) 효과로 인해 실질적인 헤지 필요량이 감소한다는 사실이다. 예컨대, KODEX200 ETF와 TIGER200 ETF처럼 동일한 기초지수(KOSPI200)를 추종하는 ETF 간에는 포지션이 서로 상쇄될 수 있다. LP가 KODEX200 ETF에 대해 매수 체결 포지션 +150억 원과 TIGER200 ETF에 대한 매도 체결 포지션 -100억 원을 동시에 보유하는 경우, 양 ETF가 동일한 기초자산군을 기반으로 하기 때문에 순포지션(net position)은 +50억 원으로 계산된다. 이때 실제 헤지 필요액은 50억 원에 불과하며, LP가 선물로 60억 원을 헤지하면 헤지비율은 24%

81) 여기서 개별 거래가 ETF 전체 위험을 대상으로 한 정당한 헤지에 해당하는지 여부는 추가적인 검토를 요한다. 예컨대 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율을 현저히 초과하여 집중되고, 다른 구성 종목이 상대적으로 언더헤지 상태에 놓이는 경우, 전체 거래대금 기준의 헤지비율이 충족되더라도 해당 거래는 ETF 전체 위험을 대상으로 한 정당한 헤지로 보기 어렵다. 이러한 경우는 개별 종목의 가격 변동에 대한 방향성 배팅을 포함할 가능성이 있다.

82) 서울고법 2010나71761 판결은 대법원 2013다3811에 의해 파기환송되었으나, 파기 사유는 헤지비율 자체의 부적정성이 아니었다. 대법원은 ① 전체 거래량 대비 60%라는 높은 시장점유율, ② 종가 결정 직전 시간대(14:50~15:00)의 집중 매도, ③ 조기상환 조건 성취 여부에 따른 이해상충 구조, ④ 이러한 상황에서 종가 형성에 직접 영향을 미친 거래 방식을 종합하여 위법성을 판단하였다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다3811). 즉, "과도한 헤지비율"이 아닌 "시장가격 형성에 부당한 영향을 미치는 거래 방식"이 위법사유였다. 따라서 115%라는 수치 자체는 법원에 의해 부정되지 않았으며, 비선형 구조의 ELS에서조차 재판상 검토된 수준이라는 점에서, 델타값이 안정적인 선형 ETF에는 더욱 타당한 기준으로 기능할 수 있다.

(60/250)으로 계산된다. 따라서 통합헤지 구조에서는 netting 효과 자체가 일종의 '내재적 버퍼'로 작용하며, 개별 거래 단위가 아닌 순포지션 기준으로 헤지비율을 산정할 경우 115% 기준은 실질적으로 더 보수적인 수준이 된다⁸³⁾.

이상의 근거를 종합하면, 115%는 실무적 제약, 판례, 그리고 통합헤지의 구조적 특성을 모두 고려한 합리적 기준으로 볼 수 있다. 다만, 본 기준은 판례와 실무 분석에 기초한 것으로, 향후 국내 ETF 시장의 실제 LP 거래 데이터를 통한 실증적 검증을 거쳐 보다 정밀한 기준(예: 110% 또는 105%)으로 조정될 여지가 있다. 현 단계에서는 판례 법리와의 정합성, 실무적 수용 가능성, 감독당국의 감독 용이성을 종합적으로 고려하여 115%를 제안한다⁸⁴⁾.

- 0~115% : Green Zone (적법 추정)

- 116이상% : Gray Zone (소명 필요)

나아가 116% 이상이라도 레버리지 및 인버스 등 민감도가 1이 아닌 ETF의 거래 등 정당한 사유가 있을 수 있으므로, 비율만으로 위법을 판단하지 않고 개별 사안의 구체적 정황을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(3) 목적성 판단기준

목적성은 행위자의 내심으로 직접 판단하기 어렵다. 따라서 대상성·비례성을 종합하여 추정해야 한다. 다만, 상품 특성(레버리지 배수 등)으로 인한 비례성 이탈이 있다고 해서 목적성이 당연히 부정되는 것은 아니며, 리밸런싱 등으로 인해 신규 대상성이 없는 것처럼 보이더라도 기존 포지션의 위험을 관리하기 위한 정당한 목적이 명확한 경우에는 여전히 목적성이 인정될 수 있다. 결국 목적성 판단은 형식이 아니라, 거래가 실제 위

83) 동일 ETF 또는 동일한 기초자산을 추종하는 상이한 ETF에서 매도와 매수가 모두 발생하더라도, LP가 이를 단순히 넷팅 처리하지 않고 개별적으로 헤지거래를 수행할 필요성이 존재한다. 양방향 체결 사이의 가격변동으로 손실이 발생할 수 있기 때문이다(예: T1 시점 NAV 10,000원에서 ETF 10,015원 매도 → T2 시점 NAV 10,100원에서 ETF 10,085원 매수 → 70원 손실). 따라서 매도·매수가 양방향으로 발생하였다는 사실만으로 헤지거래의 필요성을 부정할 수는 없다.

84) 본 기준은 감독당국의 모니터링 및 검사 실무에서 1차 선별 기준으로 기능할 수 있다. 통상 범위(0~115%)의 거래는 정당한 헤지로 추정할 수 있지만, 대상성 또는 목적성에 의문이 있는 경우에는 별도 검토의 대상이 된다. 115% 초과 거래는 적법성이 자동으로 부정되는 것이 아니라 정당화 사유에 대한 추가 소명이 요구된다.

협회피라는 합리적 목적에 근거했는지 여부에 달려 있다.

2. 해석이 필요한 거래

(1) 해석의 전제: 헤지거래의 구조와 설정 방식의 이해

(가) 포지션 방향성 표기 방식 및 헤지의 기본 구조

포지션 방향을 명확히 구분하기 위해 다음과 같은 표기 방식을 사용한다.

표기 원칙: 매수 포지션(Long): + (가격 상승 시 이익, 하락 시 손실),

매도 포지션(Short): - (가격 하락 시 이익, 상승 시 손실),

플랫(Flat): 0 (순포지션 없음)

예시: ETF 매수 +100억 원, 선물 매도 -100억 원 → 합계 0 (플랫)

(나) 헤지의 기본 원리

LP의 헤지거래는 보유 포지션과 반대 방향의 거래를 통해 가격 변동 위험을 제거하는 것이다. ETF 매수 포지션(+)을 보유한 경우 가격 하락 위험에 노출되므로, 기초자산 차입공매도(-) 또는 선물 매도(-)로 헤지한다. 반대로 ETF 매도 포지션(-)을 보유한 경우 가격 상승 위험에 노출되므로, 기초자산 매수(+)또는 선물 매수(+)로 헤지한다. 양 방향 포지션의 합이 0이 되면 플랫 상태, 즉 완전 헤지가 달성된다.

(다) 설정(Creation) 프로세스에서의 헤지 필요성

ETF 설정 시 기초자산 조달 방법에 따라 헤지 필요성이 달라진다. 차입설정인 경우, LP는 기초자산을 차입하여 운용사에 납입하고 ETF를 수령한다. 이 경우 차입한 기초자산 포지션(-)과 수령한 ETF 포지션(+)이 자동으로 상쇄되어 플랫 상태가 되므로 추가 헤지가 불필요하다. 반면 매수설정의 경우, LP는 기초자산을 시장에서 매수(+)하여 납입하고 ETF를 수령(+)한다. 이때 LP는 가격 하락 위험에 노출됨으로, 선물 매도(-)로

헤지하여 플랫 상태를 유지해야 한다. 실무상 대부분의 LP는 차입설정 방식을 선호한다. 운용사로부터 저리로 기초자산을 차입할 수 있어 자금 조달 비용이 낮고, 매수설정과 달리 선물 헤지 비용이 추가로 발생하지 않기 때문이다. 다만 운용사의 해당 ETF가 대차 비율 한도에(50%)⁸⁵⁾ 도달한 경우 등에는 불가피하게 매수설정을 선택할 수밖에 없다.

(2) 신규 ETF 거래 없이(유동성공급 없이) 헤지자산의 변경

(가) 리밸런싱 등

- 기초지수 구성 종목 변경 (A종목 편입, B종목 편출)
- 구축 포지션: 해당 ETF 매수 (Long) 및 기초자산 차입공매도(Short)
- LP의 대응: A종목 차입공매도, B종목 매수 (리밸런싱 추종하는 헤지 포지션 조정)

설명: 신규 ETF 거래가 없더라도 기초지수 구성 종목의 편입·편출 등 외부적 요인으로 인해 기존 ETF의 구성자산이 변경되는 경우, LP는 이에 대응하여 헤지자산을 조정할 수밖에 없다. 이러한 거래는 ETF 운용사나 LP가 통제할 수 없는 외부 사건에 따른 불가피한 조정이며, 실제로 조세특례제한법 제117조 제21호가 ETF 운용사의 리밸런싱 거래에 대해 증권거래세를 면제하고 있는 점은, 리밸런싱이 지수 추종이라는 ETF의 본질에서 비롯된 불가피한 대응 거래임을 인정한 것으로 볼 수 있다.

따라서 ETF를 보유한 LP가 기초지수 변경에 따라 편입 종목을 차입공매도(-)하고 편출 종목을 매수(+)하는 행위는, ① 손실 방지라는 명백한 위험회피 목적(목적성), ② 편입·편출 비율에 비례하는 거래 규모(비례성)가 모두 충족된다. ③ 신규 ETF 거래(대상성)는 없으나, 지수 변경이라는 LP가 통제할 수 없는 외부적 사유로 인해 기존 포지션에서 새로운 형태의 위험이 발생하였고, 이에 대응하는 것이 헤지의 본질이라는 점에서 정당한 헤지거래로 인정된다. 결국 이러한 리밸런싱 대응 거래는 신규 유동성공급 행위가 없다고 하더라도 정당한 헤지거래로 평가함이 타당하다. 아울러 이 논리는 ETF가 편입한 기초자산의 무상증자, 주식합병 등 기초자산의 권리 변동으로 인한 포지션 조정에도 동일하게 적용될 수 있다.

85) 한국금융투자협회, 펀드의 증권대차거래 업무 가이드라인, 모범규준 제7조 (2023).

(나) 선물 만기대응 헤지 자산 전환

－ KODEX 200 매수: 80억 원＋

－ 3월물 선물 매도: 80억 원－

→ 헤지 목적 달성: 리스크 중립 상태 유지

설명: 위와 같은 상황에서 선물 만기도래로 인하여 LP는 기존 위험을 동일한 헤지수단으로 롤오버할 수도 있고, 선물을 청산하고 현물로 헤지자산을 전환할 수 있다. 이때 헤지자산 교체는 외형상 신규 포지션의 개시로 볼 수 있으나, 그 목적과 경제적 실질이 기존 헤지와 동일하다면 정당한 헤지거래로 평가될 수 있을 것이다. ETF LP는 만기 이후에도 동일한 기초자산 위험에(KODEX 200 80억원＋) 노출(대상성)되어 있으므로, 선물 만기는 단지 헤지수단의 계약기간 종료에 불과하다고 볼 수 있다. 또한 선물 만기는 외부적 요인에 의해 발생하므로, 이를 회피하기 위한 교체는 투기적 거래가 아닌 위험회피 행위(목적성)로 보아야 한다. 따라서 헤지 전환 규모(비례성)도 적절하다면 정당한 헤지거래로 볼 수 있다. LP에게 최초 헤지수단만을 고수하도록 강제하는 것은, 시장 여건 변화에 따른 불필요한 헤지 비용 증가나 헤지 효율성 저하를 감수하게 하는 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

(다) 만기 전 헤지 자산 전환

다만, 헤지자산 전환의 정당성은 전환 시점에 따라 달리 평가되어야 한다. 만기 시점의 전환은 필연적인 의사결정 시점에서 이루어지는 것으로, LP의 합리적 재량 범위 내 행위로 인정된다. 반면 만기 전에 이루어지는 헤지자산의 전환은 원칙적으로 새로운 위험(대상성)이 존재하지 않으므로, 정당한 헤지로 보기 어렵다. 이 경우 명백한 사정이 없는 한 위험회피 목적(목적성)도 인정되기 어렵고, 따라서 비례성 요건 충족 여부와 무관하게 정당성이 부정된다. 다만, 다음과 같이 아주 예외적 상황에서만 가능할 수 있고, LP는 이를 입증해야 한다.

① 선물시장 유동성 급감으로 정상적인 롤오버가 불가능할 것이 명백한 경우

② 기초자산 합병 등에 따른 주식 선물의 상장폐지 등

(3) 선행헤지

(가) ETF 설정을 위한 선행헤지

- ETF의 기초자산을 차입설정이 아닌 매수설정 시
- PDF 매수 +80억 원
- 동시에 선물매도 -80억 원 (선행 헤지)
- 이후 ETF 설정 완료 → 유동성공급

설명: LP는 ETF 유동성공급을 위해 일정 물량을 확보할 필요가 있으나, 매수설정을 할 경우(예: 펀드 대차 한도 초과, 대차시장 유동성 부족 등)에는 기초자산 바스켓(PDF)을 직접 매수하여 ETF를 설정해야 한다. 이 과정에서 PDF 매수(+)와 동시에 선물매도(-)를 수행하는 선행헤지는, 물량 확보와 위험 관리를 동시에 달성하기 위한 합리적 거래에 해당한다. 선행헤지가 없다면 LP는 PDF 매수 시점부터 가격 변동 위험에 노출된다. 특히 매수설정 방식에서는 PDF 매수(+)와 ETF 수령(+)이 동일 방향 포지션이므로, 설정 완료 후에도 가격 하락 위험이 지속된다. 따라서 이러한 거래는 ① 대상성: PDF 매수로 인한 위험이 실제로 존재하고, ② 목적성: ETF 설정을 위한 물량 확보 과정에서 해당 위험을 회피하기 위한 것이며, ③ 비례성: 헤지 규모가 실제 위험에 비례한다면, 정당한 헤지거래로 평가될 수 있다.

(나) ETF 설정을 위한 선행헤지 후 환매 PDF의 매도

- LP가 ETF 설정 목적으로 PDF 매수 + 선물매도 (선행헤지)
- ETF 설정 완료 → ETF 보유 (+), 선물 헤지 (-)로 플랫폼 유지
- 보유 상태*: ETF +80억 원 (선물 -80억 원으로 헤지 중, 리스크 중립)
 - * 유동성공급을 위해 매도호가를 제출하였으나 체결되지 않아 보유하게 된 물량
- T일: ETF 환매 신청
- T일: 환매로 받을 PDF 선매도 -80억 원 (공매도 예외 적용 가능⁸⁶⁾)

86) 자본시장법 제180조 제2항 제3호 및 동법 시행령 제208조 제3항 제3호(상장지수집합투자기구

- T일: 선물 매도 포지션 청산 (매수) +80억 원

- T+2일: 환매로 PDF 입고, 선매도 결제

설명: LP가 ETF를 보유(+한 상태에서 이미 선물 매도(-)로 완전한 헤지를 유지하고 있다면, 이후 ETF 환매를 신청하면서 환매로 수령할 PDF를 선매도(-)하고 기존 선물 포지션을 청산(+하는 행위는 형식상 헤지거래처럼 보이지만, 실질적으로는 새로운 위험(대상성)이 발생하지 않은 상태에서 이루어진 포지션 정리 또는 차익 실현 행위에 가깝다. ETF 설정을 위한 선행헤지는 PDF 매수 시점부터 시장 위험이 발생하므로 헤지의 필요성이 인정되지만, 환매 시점의 PDF 선매도는 이미 리스크 중립(플랫) 상태에서 이루어지는 것으로, 위험회피 목적(목적성)을 인정하기 어렵다. 특히 음의 괴리율(ETF 시장가격 < 순자산가치, NAV) 상황에서의 PDF 선매도는 LP에게 추가 이익을 가져다주는 차익거래로 해석될 여지가 높다. 따라서 ETF 설정을 위한 선행헤지 후 환매 PDF의 조기 매도는 대상성 부재 및 목적성 결여로 인해, 비례성 요건과 무관하게 정당한 헤지거래로 인정되기 어렵다. 다만, 해당 ETF의 상장폐지가 확정되어 환매가 유일한 출구인 경우, ETF 시장 거래정지로 정상적인 매도가 불가능한 경우 등 특별한 사정이 있다면 예외를 인정할 수 있다. 이러한 예외 사유는 LP가 입증할 책임을 부담한다.

(다) 장외 블록딜 선행헤지

- 14:00: 대형 기관으로부터 A ETF 100억 원 규모 블록딜 매도 요청

계약 내용 확정 (가격은 종가 NAV + 수수료 등 조건 확정)

- 14:10: 기초자산(현물 또는 선물) 매수 +100억 원 (선행 헤지)

- 15:10: 블록딜 체결 (ETF 매도 -100억 원)

설명: ETF 블록딜은 거래 규모가 크고, 특히 장 마감 임박 시점에는 체결 후 즉시 헤지를 수행하기 어렵다. 또한 동시호가 시간대(15:20~15:30)는 유동성이 급감하고 호가 스프레드가 확대되어 시장 충격을 유발할 가능성이 높다. 따라서 거래 가격이 종가 NAV 기준으로 사실상 확정된 경우, LP가 블록딜 요청을 수락하고 계약의 핵심 조건이 합의된 시점부터는 대상 위험이 이미 발생했다고 볼 수 있다(당사자가 합의할 수 있는 조건

의 집합투자증권의 환매청구에 따라 받게 될 상장증권의 매도)에 따라 공매도로 보지 아니한다.

도 모두 합의되었다고 볼 수 있다).

이러한 상황에서 시장 충격을 방지하고 가격 변동 위험을 통제하기 위한 선행 헤지는 ① 대상성: 거래 체결이 확정된 이상, 대응해야 할 위험이 존재하고, ② 목적성: 헤지 목적이 수익 추구가 아니라 시장안정과 위험회피에 있으며, ③ 비례성: 헤지 규모가 예정된 거래 규모를 초과하지 않는다면, 정당한 헤지거래로 평가될 수 있다. 다만, 블록딜 확정적 객관적 증빙(녹취, 이메일, 체결 약정 등)이 명확히 존재해야 한다(블록딜 매수 요청인 경우에도 동일한 기준으로 판단할 수 있다)⁸⁷⁾.

[표 2] ETF LP 정당한 헤지거래 판단 가이드라인

구분	판단기준	주요국 규율	확인사항	위반의심
대상성	헤지거래 주문 시점에 헤지 대상 포지션 및 관련 리스크가 실제 존재하는가?	미국: specific, identifiable risk (Volcker Rule) / 캐나다: risk from prior·subsequent transactions (UMIR §1.1) / 시장조성 활동에서 발생하는 포지션의 헤지(SSR Art.2(1)(k)) / 호주: 선행헤지 배제 원칙, 다만 가격 확정 시 예외 (ASIC RG 196.57, 196.59) / 홍콩: 기존 포지션 헤지에 한정	① 체결시점 ETF 매도/매수 수량과 헤지거래 자산 수량(선물/주식바스켓 등) 맵핑 ② LP 계약상 스프레드·과리율 유지의무 준수 여부 및 양방향 호가 제출 확인	ETF 포지션 없이 선물 또는 현물만 거래 · 단방향 호가 제출만 반복되거나 IOC 주문방식으로 즉시 체결이 주를 이루어 유동성공급의 실질이 의문시되는 경우 · 다만 블록딜·매수 설정 등 선행헤지가 인정되는 예외적 경우 존재(V장

87) 장외 블록딜 거래를 LP의 유동성 공급행위로 볼 수 있을까 하는 의문이 제기될 수 있다. LP의 호가제시 의무는 거래소 시장 내에서의 활동을 전제로 하며, 장외 블록딜은 특정 기관과의 거래로서 불특정 다수에 대한 유동성 공급과는 성격이 다르게 보이기 때문이다. 그러나 LP가 기관의 블록딜 요청을 거부할 경우, 해당 기관은 거래소 시장에서 ETF를 대량 매매할 수밖에 없고, 이는 ① 급격한 과리율 확대, ② 호가 스프레드 급등, ③ 종가 형성 왜곡 등 시장 전체의 불안정을 초래할 수 있다. 특히 동시호가 시간대(15:20~15:30)의 대량 주문은 일반 투자자에게 직접적 피해를 야기할 가능성이 높다. 더욱이 실무상 ETF 블록딜은 장외에서 가격을 협의(일반적으로 종가 NAV+헤지비용)하더라도 최종 체결은 한국거래소의 대량매매시스템(K-blox) 등 거래소 인프라를 통해 이루어지는 경우가 많아, 완벽한 장외거래라기보다 거래소 시장 기능의 연장선상에 있다고 볼 수도 있다. 따라서 LP의 블록딜 거래는 유동성공급업무의 실질적 이행으로 평가될 수 있을 것이다. 호주 ASIC도 동일한 취지에서, 시장조성자가 거래의 핵심 조건에 합의하였으나 사전에 정해진 조건이 아직 충족되지 않은 단계에서의 헤지는 선행헤지에 해당하지 않는다고 보며, 특히 상품의 가격이 헤지 가격에 의해 결정되는 구조에서는 더욱 그러하다고 본다(ASIC RG 196.59). 블록딜의 가격이 종가 NAV에 헤지비용을 반영하여 결정되는 구조는 이에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

		(SFC §2.5.4(f))		2절 사례)
목적성	헤지거래의 주된 목적이 위험회피인가? 투기·차익추구가 주목적은 아닌가? ※ 다만, 대상성이 명백히 충족되는 경우 결과적 차익 발생만으로 목적성 위반으로 보지 않는다.	미국: bona fide market making, 투기 목적 명시적 금지 (Volcker Rule) / 캐나다: hedger 개념, 투기자 배제(UMIR) / EU: 정당한 사유 및 인정된 시장관행 부합 여부 (MAR Art.9)	① 거래 전후 위험지표 (순익스포저) 변화 - 헤지 후 위험이 실제로 감소하였는가? ② 헤지 방향과 보유 포지션 방향의 일관성 ③ 공매도 금지 기간 중 예외거래 비중의 변화 추이 등	수익 목표·방향성 배팅을 내부적으로 지시·평가하는 정황 · 백워데이션 등 구조적 수익 환경에서 헤지 명목 차입공매도가 집중되는 경우 · 증가시간대 등 특정 시간대에 거래가 반복적으로 집중되는 패턴 · 대상성·비례성을 종합하여 판단
비례성	헤지 규모가 실제 위험 노출에 비례하는가? [1차 스크리닝] 통합헤지비율 115%를 감독상 참고기준으로 적용 [개별 거래] 통합비율 충족 여부와 별도로, 개별 거래 수준의 비례성을 검토	미국: proportional to risk(Volcker Rule) / 캐나다: no more than offset(UMIR) / EU: 헤지 규모가 대상 익스포저에 비례할 것, 불일치 시 소명 의무(ESMA Guidelines) / 영국: 행위가 부담한 위험에 비례하는지 여부 (FCA MAR 1.3.15G(4))	① 통합헤지비율 산정: 전체 헤지 거래대금 / 전체 ETF 거래대금 (115% 이내 여부) ② 레버리지·인버스 ETF의 경우 헤지 방향 및 규모가 해당 ETF의 민감도 특성에 부합하는지 확인 (예: 레버리지 2배 → 반대방향 2배, 인버스 → 동일방향 1배 등) ③ 개별 종목별 헤지 배분: 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율 대비 적정한지 ④ 동일 기초자산을 추종하는 복수 ETF에 대한 통합헤지 로직의 처리 방식 및 개별 종목별 헤지비율과의 정합성 검증	통합헤지비율이 115%를 초과하며 정당화 사유가 소명되지 않는 경우 · 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율을 초과하여 집중되고 다른 종목이 언더헤지 상태인 경우(방향성 배팅 가능성) · 다만 수치만으로 적법·위법을 단정하지 않으며, 최종 판단은 대상성·목적성 및 개별 사안의 구체적 정황을 종합적으로 고려함
사전 문서화 및 내부통제체계	대상성·목적성·비례성의 3대 기준이 내부적으로 통제 가능한 체계 하에서 운영되고 있는가?	미국: 헤지 전략 문서화 의무, 지속적 검토·재조정, 독립적 검증 및 내부통제 프로그램 운영, 보상체계 중립성(Volcker Rule §248.5(b)(1)(i), (b)(1)(ii)(D), (b)(1)(iii), (c)(2))	① 내부 헤지 정책·기준 문서의 존재 여부(헤지 목적, 허용 수단, 비율 기준 등) ② 통합헤지·자동헤지 프로그램 로직 및 실제 체결 결과의 정합성 확인 - 자동헤지가 아닌 수기 주문의 경우	헤지 정책·기준 문서가 전무한 경우 · 자동헤지 프로그램 로직과 실제 체결 결과 간 유의미한 괴리가 확인되는 경우 · 수기 주문이 빈번함

			별도 소명 ③ 북(book) 한도 통제 및 건전성 관리 체계를 통한 헤지 한도 승인·관리 여부 ④ 사후 감사 기록 - 헤지 실행 결과에 대한 내부 검증 절차의 존재 여부	에도 그에 대한 소 명이 부족한 경우
--	--	--	--	-------------------------

3. 소결

본 장은 ETF LP 헤지거래의 적법성을 판단하기 위한 대상성·목적성·비례성의 3대 기준을 정립하고, 이를 실제 거래 유형에 적용함으로써 정당한 헤지의 실질적 판단기준을 제시하였다. 대상성·목적성·비례성은 각각 헤지의 실재, 위험회피의 정당성, 헤지 규모의 적정성을 판단하기 위한 기준으로서, 개별적으로가 아니라 종합적으로 고려되어야 한다. 또한 실무상 해석이 필요한 복합 거래에 대해, 본 논문은 리밸런싱, 헤지자산 전환, 선행헤지 등 다양한 사례를 통해 외형상 복잡한 거래라도 위험의 실재와 목적의 정당성, 규모의 적정성이 입증된다면 정당한 헤지로 인정될 수 있음을 확인하였다.

VI. 결론

본 연구는 ETF LP의 헤지거래를 둘러싼 법적 공백을 메우고자 하였다. 공매도 금지 조치 기간 중 LP에게만 허용된 '헤지 목적' 예외는 지속적으로 형평성 논란을 야기해왔으나, 정작 '정당한 헤지'가 무엇인지에 대한 논의는 존재하지 않았다. 이에 본 연구는 국내 판례와 주요 국 규제체계를 분석하여 대상성·목적성·비례성의 3대 판단기준을 도출하고, ELS 델타헤지 판례에 기초하여, 감독상 참고기준으로서 헤지비율 115%를 잠정 제안하였으며, 리밸런싱·선물 만기 전환·블록딜 선행헤지 등 실무상 복합 거래에 대한 유형별 적법성 판단기준을 정립하였다.

제도 개선의 방향은 명확하다. LP의 유동성 공급은 ETF 시장의 효율적 운영에 필수적이

나, 그 활동이 정당한 범위 내에서 이루어지기 위해서는 명확한 법적 기준이 필요하다. '정당한 헤지거래'의 정의 및 비례성 판단기준은 법령·규정·가이드라인 등 제도적 수준에서 명확히 정립할 필요가 있으며, 선물 헤지계좌 신고 의무를 실질화하고 통합·자동헤지 프로그램에 대한 감독 기준을 마련하여 감독 사각지대를 해소해야 한다.

다만 본 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 115% 기준은 판례 법리와 실무 분석에 기초한 잠정적 수치이며, 향후 국내 ETF LP의 실제 거래 데이터에 대한 실증 분석을 거쳐 보다 정밀하게 조정될 필요가 있다. 또한 본 연구가 다룬 유형별 사례는 실무상 주요 거래를 중심으로 선별한 것으로, LP 헤지거래의 모든 형태를 포괄하지는 못한다. 특히 장외파생상품을 활용한 헤지거래 등에 대해서는 별도의 후속 연구가 요구된다. 아울러, 본 연구가 제시한 115%는 통합헤지 비율에 대한 감독상 스크리닝 기준으로서, 개별 헤지거래의 적정 비율과는 판단의 층위가 다르다고 할 수 있다. 개별 거래 수준의 비례성 기준을 정밀하게 설정하기 위해서는 실제 LP 거래 데이터의 축적과 이에 기반한 실증 분석이 선행되어야 하며, 이는 후속 연구의 과제로 남긴다.

그럼에도 국내 ETF 시장이 순자산 300조 원⁸⁸⁾을 돌파하고, 2024년 미국의 비트코인 ETF 승인 이후 국내에서도 가상자산 ETF 도입 논의가 본격화되고 있는 현재, LP 헤지거래에 대한 법적 기준의 부재는 더 이상 방치할 수 없는 과제라고 생각한다. 주식형 ETF에서 정립된 헤지거래 법리는 새로운 자산군으로의 확장을 위한 이론적 기반이 될 수 있으며, 본 연구가 제시한 판단기준이 LP의 예측가능성 제고, 감독당국의 일관된 집행, 그리고 투자자 보호를 동시에 실현하는 제도적 출발점으로 기여할 수 있기를 기대한다.

88) 한국경제 (2026.1.6.) ‘불장 타고 질주한 ETF 순자산 300조원 넘었다’.

참 고 문 헌

- 김주영, 2011, "헤지거래기법을 이용한 투기거래와 이에 대한 법적 규제" 증권법연구, 제12권 제3호,
- 김민기·김준석, 2023, ETF가 주식시장에 미치는 영향, 자본시장연구원 연구보고서, 23-03.
- 김세완·김민주·김영민, 2024, "ETF 지분이 기초자산 주식의 변동성에 미치는 영향 분석", 금융공학연구, 제23권 제2호.
- 김은충·황교선·전상훈, 2025, "상장지수펀드(ETF) 보유지분이 기초자산 주식의 가격 모멘텀에 미치는 영향: 한국 시장을 중심으로", 재무연구, 제38권 제1호.
- 김흥기, 2016, "ELS 델타헷지의 정당성과 시세조종에 관한 연구 - 대법원 2016. 3. 24. 선고 2013다2740 판결을 대상으로", 상사판례연구, 제29집 제2권.
- 나지수, 2016, "주가연계증권(ELS) 델타헤지거래 관련 분쟁의 분석", 증권법연구, 제17권 제1호.
- 삼성증권 글로벌투자전략팀(전균), 2022, ETF가 개별종목에 미치는 영향: KOSPI200 구성종목에 대한 ETF 편입비중 추적, Derivatives Spot.
- 류호영·김은충, 2024, "ETF 가격과리를 이용한 투자전략: 한국 주식형 ETF를 중심으로", 금융공학연구, 제23권 제3호.
- 송준혁·이창일, 2020, "ETF 시장 확대가 개별 구성 주식의 행태에 미치는 효과 분석", 선물연구, 제28권 제1호.
- 우민철·김지현, 2019, "공매도를 이용한 불공정거래 개연성", 한국증권학회지, 제48권 제1호.
- 이우백·정재만, 2022, "한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석", 재무관리연구, 제39권 제4호.
- 한국거래소, 주식시장 매매제도의 이해, 2019.

■ 금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

Legal Framework for Hedging Transactions by ETF Liquidity Providers in Korea

– A Comparative Analysis and Reform Proposal

Lee Kyungmin*

Abstract

This study establishes legal standards for determining legitimate hedging transactions by Exchange-Traded Fund (ETF) Liquidity Providers (LPs). During short-selling bans, LPs are granted an exclusive "hedging-purpose" exemption, yet the Korean Capital Markets Act contains no definition or criteria for bona fide hedging, giving rise to recurrent fairness concerns. The current regulatory framework lacks a substantive definition of hedging transactions: Enforcement Decree provisions rely on broad formulations without operational criteria or proportionality standards, and supervisory rules provide no structured oversight of LP hedge accounts.

A comparative analysis of Korean case law (currency hedging, KIKO, and ELS delta-hedging) and foreign regulatory regimes in the United States, Canada, and the European Union reveals three shared principles of legitimate hedging: specificity (an identifiable underlying exposure), purposefulness (genuine risk mitigation rather than speculation), and proportionality (hedge size not exceeding actual risk exposure). Major jurisdictions institutionalize these principles through the Volcker Rule, UMIR, and MAR, whereas Korea lacks even principle-level codification. Drawing on proportionality reasoning articulated in Korean precedents—particularly ELS delta-hedging cases—this study proposes 115% as a supervisory reference threshold for portfolio-level screening, grounded in case-law interpretation, and presents a structured assessment guideline—incorporating ex-ante documentation and internal control requirements—for complex LP activities such as portfolio rebalancing and futures rollovers.

The study concludes that Korea should codify definitions and proportionality standards for hedging transactions through laws, regulations, or supervisory guidelines. Where an LP's transaction fails to satisfy the substantive requirements of the hedging exemption, appropriate enforcement measures should follow. Such reforms would close regulatory blind spots, enhance legal predictability for LPs, and promote consistent supervisory enforcement. The proposed framework provides precedent for regulatory harmonization across derivative-linked products and emerging asset classes.

Key words: ETF Liquidity Provider, Hedging Transactions, Bona Fide Market Making, Short Selling Regulation
JEL Classifications:: K22, G18

* Senior Manager of Financial Supervisory Service (leekm@fss.or.kr)